

Al respecto no puede dejar de citarse la propuesta de reforma por los ex diputados Quarrachino y Aramouni, pues no solo no olvida lo relativo al control, sino lo desarrolla en forma previa. Allí se establece que "vetada en parte una ley por el Poder Ejecutivo, esto sólo puede promulgar la parte no vetada, si ella tuviera autonomía normativa y la afectare la unidad, **previa decisión favorable por parte de la Cámara de Origen**" (el destacado es nuestro). Es de destacar que en el derecho público provincial sólo una minoría de las Constituciones reformadas admite la promulgación de la parte no vetada de un proyecto que ha sido objeto de veto parcial del Ejecutivo. Pero, en estos casos, la modalidad se ve acompañada del control previo a la promulgación por parte de la Cámara de origen (conf. Constitución de Córdoba art. 114, 2ª parte). El interrogante que nos quedaría para analizar se centraría en la continuidad de dicha exigencia por parte de la cámara de origen cuando en las provincias exista una sola Cámara —teniendo en cuenta los recientes proyectos de reforma en las constituciones provinciales, transformando en Unicameras a sus Legislatura, por razones de economía presupuestaria—. Creemos en primer término que la denominación debería modificarse ya que no existe una Cámara de origen y otra revisora; en segundo lugar, si bien es cierto que al haber una completa discusión parlamentaria la misma se tornaría innecesaria; sin embargo, al exigirse la aprobación por parte de la Legislatura, se estaría efectuando un control previo, formando reaseguros eficaces sin atentar contra el mentado equilibrio de poderes.

Ahora bien, la Constitución Nacional le ha conferido dicha facultad de promulgación al órgano ejecutivo y este órgano es el encargado, según su criterio, de sancionar parte de una ley que considera necesaria y que el proyecto no constituye un todo inescindible. No olvidemos que es el mismo órgano habilitado para el ejercicio de dicha instrumentación, quien determinará en qué caso la promulgación procede, sin que se prevea ningún control previo al respecto.

Por otro lado, al ser una función netamente política formando parte del proceso de formación de las leyes, su conducta no es susceptible de revisión judicial, quedando impedido de suplir la manifestación de voluntad que ha efectuado el Poder Ejecutivo con una resolución judicial.

Aunque, como es sabido, las garantías del debido proceso adjetivo exigen el cumplimiento de los mecanismos formales dispuesto en la Constitución para la sanción de normas, reglas todas ellas diseñadas para evitar los desbordes del poder y facilitar los controles mutuos. Por su parte, el principio de legalidad impone la existencia de una ley formal y debidamente dictada por el Congreso para reglamentar los derechos constitucionales.

Todo ello nos indica, para que una ley sea tal, requiere la participación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, más el control de constitucionalidad del Poder Judicial, y no de uno solo, por razones que hacen al sistema de "*checks and balances*" o pesos y contrapesos, es decir, como técnica inherente a la aplicación del principio de la separación y distribución equilibrada de los poderes del Estado, o como afirmaba Montesquieu "es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder".

Así pues, que si bien la potestad legislativa directa en la promulgación parcial de ley, no ostenta un control *a priori*, sin embargo podría decirse que sí existe un doble control *a posteriori*: A) jurisdiccional y, B) legislativo.

A) **Control judicial**: Sostener que las promulgaciones parciales de las leyes sólo están sujetas al control parlamentario establecido por el art. 80 "in fine" de la Constitución Nacional y sin intervención del Poder Judicial se estaría llegando a un absurdo donde el Poder Judicial invalida leyes, decretos o actos administrativos pero no lo atinente a las leyes parcialmente promulgadas. Por ello y dado que inveterada jurisprudencia se ha expedido sobre la judiciabilidad de este tipo de procedimiento a lo largo de los años, no se ve ningún motivo para que no siga interviniendo, más aún que los Tribunales cumplen una actividad institucional en su carácter de guardián e interprete final de la Ley Fundamental en orden al adecuado respeto del principio de separación de los poderes del Estado consagrado en aquélla, y para asegurar, como titular de unos de ellos, su coordinado accionar.

De esta forma el control judicial verificará si el veto ha dejado inalterado el objeto central de la ley, ya que las normas observadas han podido escindirse del proyecto total sancionado por el Congreso, sin detrimento de aquél.

Al analizar esta función se señala que puede basarse en motivos de necesidad o conveniencia para el país, o bien en razones de inconstitucionalidad del proyecto de ley. Pero es indudable que esa facultad de órgano controlante no puede ser ejercida en forma discrecional e indiscriminada; de modo que, el juez competente deberá exponer las razones malas o buenas que lo han llevado a tomar dicha decisión, sin adentrarse en el análisis fáctico de dicha medida, cuya decisión es netamente política.

B) **Control legislativo**: Se encuentra establecido en el mismo art. 80 de la Constitución Nacional donde en su parte final establece que para este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia, es decir, que requiere la aprobación del Congreso de la Nación.

La remisión efectuada al art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional es sólo procedimental, es decir, no necesariamente debe cumplir con las exigencias de admisibilidad establecidas en el párrafo tercero del citado inciso, ya que dicha requisitoria sólo se da para los decretos de necesidad y urgencia y, no en la promulgación parcial de la ley. Insistimos, no es un decreto de necesidad y urgencia sino un decreto de promulgación con las mismas condiciones de tiempo y forma en su contralor que el decreto de necesidad y urgencia. La ley que reglamente esta intervención deberá seguir estos lineamientos si no se quiere perder la naturaleza de dicho instituto.

4. COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE

Como hemos señalado en el capítulo anterior, la ley 26.122 disciplinó de manera conjunta este mecanismo de control previsto constitucionalmente,

tanto para los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes (art. 1º, ley cit.), luego de doce años de demora congressional (3).

5. EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL

En uno de los primeros fallos de mayor trascendencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejó sentado en el caso "*Giulitta Orenco*" (Fallos 189:156), que el veto parcial y la promulgación fragmentaria de un proyecto de ley, no se excluyen recíprocamente y son independientes, y el primero produce por lo menos, el efecto de suspender la promulgación de la ley con relación a la parte vetada, o sea, impedir que tenga lugar la promulgación tácita.

Luego, el Máximo Tribunal, en los autos "*Colella Ciriaco*" del año 1967 (Fallos 268:352) cuyos fundamentos más importantes fueron receptado por la reforma del año 1994 en el art. 80 de la Constitución Nacional, estableció la viabilidad de la promulgación parcial, siempre que no se altere su unidad y sentido. La Corte consideró que el proyecto sancionado por el Poder Legislativo constituía un todo inescindible, de modo que las normas promulgadas no han podido separarse del texto legal sin detrimento de la unidad de éste. Como regla, las disposiciones que componen una ley están vinculadas entre sí. El Poder Ejecutivo no pudo proceder como lo hizo, sin invadir atribuciones propias del Congreso, y sin asumir él, la especie y la calidad de legislador. Debe admitirse que la promulgación parcial que se analiza es inconstitucional, y por lo tanto, faltando promulgación, la ley no es tal. Por ello, los fundamentos concordantes de la sentencia apelada, y del dictamen del Procurador General se confirma el fallo apelado, en cuanto fue materia del recurso extraordinario.

Esta jurisprudencia fue posteriormente seguida en varios precedentes (Fallos: 318:445, consid. 7; 319:1479) donde sin abrir juicio de un modo general sobre el régimen de promulgación de las leyes entró a conocer cuestiones análogas, a fin de determinar si el proyecto sancionado por el Congreso Nacional constituía o no un todo inescindible, de manera que las normas observadas no hubieran podido separarse del texto total sin detrimento de éste.

Posteriormente, en el caso "*Sanitas Nubial S.A.*" con fecha 13/05/1999 (LA LEY, 1999-E, 786), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala I, estableció que al no haber sido creada aún la Comisión Bicameral Permanente prevista por el art. 99, inc. 3º de la Constitución Nacional a los efectos del control establecido para la promulgación parcial de las leyes—art. 80, Ley Fundamental—, no cabe considerar que el Congreso de la Nación ha declinado los poderes que le fueron conferidos constitucionalmente, sino que ellos se ejercen a través de los mecanismos previs-

(3) V. CARNOTA, WALTER F., "Por fin, se reglamentaron los decretos de necesidad y urgencia y otros remedios de emergencia", en www.eldial.com, 8/8/2006.

tos por el art. 83, parte 1ª de la Carta Magna. Por su parte la misma sala con fecha 21/03/2000, en el caso "*Samti S. R. L.*" (LA LEY, 2001-B, 451 - DJ, 2001-1-773), resolvió que no es procedente la promulgación parcial de la ley 25.063, realizada mediante el decreto 1517/98 (Adla, LIX-A, 5), en tanto la eliminación de la exención del pago del impuesto al valor agregado para los sistemas de medicinas prepagas —promulgada por el Poder Ejecutivo— y la imposición de una alícuota reducida para éstos —vetada por el referido decreto—, conforman una unidad que no podría ser desmembrada, pues independientemente, la una de la otra, carecerían de la autonomía normativa exigida por el art. 80 de la Constitución Nacional.

Sobre estos mismos argumentos, el Juzgado Nacional de la Instancia en lo Contencioso administrativo Federal Nº 1, a cargo del Dr. Ernesto Marinelli en el caso: "*Adecua*" resolvió con fecha 3/2/1999, que no es posible la promulgación parcial de la parte del proyecto de ley no vetado por el Poder Ejecutivo si no concurren las condiciones establecidas en el art. 80 de la Constitución Nacional, pues ni el despacho de la Comisión Bicameral Permanente ni su posterior tratamiento por el plenario de cada Cámara del Congreso de la Nación pueden tener por efecto su convalidación al margen de la concurrencia de tales condiciones (ver LA LEY, 1999-C, 207, con nota de Patricio Alejandro Maraniello - DJ, 1999-2-776 - IMP, 1999-A).

6. COMENTARIO AL FALLO "FAMYL S.A." (29/8/2000) (4)

a) Antecedentes fácticos y jurídicos

Con fecha 7/12/1998 se sanciona la ley 25.063, que implicó una amplia reforma al régimen tributario nacional y de la seguridad social, ya que modificó varias leyes impositivas, a la vez que introdujo dos nuevos tributos (al endeudamiento empresario y ganancia mínima presunta). Se trata de una "ley omnibus", por abarcar diferentes cuestiones que si bien están incorporadas bajo un mismo número de registro, en lo sustantivo pueden ser consideradas como disposiciones diferentes, con autonomía normativa y entidad diferenciada.

El art. 1º, inc. e), apartado 4) de la ley 25.063, derogó la exención que gozaban las prestaciones de servicios de medicina prepaga en el IVA (art. 7º, inc. h, último párrafo, punto 7, de la ley 23.349, t.o. por el dec. 280/97) y que, mediante el inc. m) del mismo art. 1º se estableció la alícuota reducida del 10,5%. Es decir que el legislador previó el hecho imponible relativo a la prestación del servicio de medicina prepaga por parte de empresas privadas que no sean obras sociales (regidas por la ley 23.660) que presten sus servicios a sus afiliados obligatorios, sobre la base del precio final del servicio con una tasa del 10,5%.

(4) Fallos 323:2256.

El Poder Ejecutivo, mediante decreto 1517/98 arts. 1º, inc. f, y 7º, vetó la norma en lo referido a la reducción de la alícuota y promulgó parcialmente la ley —aún en la parte que derogaba la originaria exención— estableciendo una alícuota general del 21%.

La sociedad —dedicada a la prestación de asistencia médica de modo directo y mediante el sistema denominado de medicina prepaga— promovió acción de amparo contra el Estado Nacional con el fin de obtener que se declarase la inconstitucionalidad de la ley 25.063, vetada y promulgada parcialmente por el dec. 1517/98 y que, en consecuencia se mantuviese la exención del IVA para la actividad que desarrolla.

Tanto el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Junín, como la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de La Plata hicieron lugar a la acción de amparo y declararon la inconstitucionalidad de los arts. 1º, inc. f, y 7º del dec. 1517/98. Este último, entendió que, de la inteligencia de los arts. 80, 83 y 99 inc. 3, de la Ley Fundamental surge que, en la especie, si bien el veto es válido, era improcedente la promulgación parcial (5), dado el carácter y naturaleza de la norma observada (inc. m, del art. 1º, ley 25.063), pues no se trata de una norma separable del resto del texto legal y la observación no mantiene la unidad, armonía y espíritu del proyecto de ley sancionado conformada en el caso por la imposición del gravamen a una actividad antes exenta, pero con la determinación de una alícuota reducida. En los hechos, la observación del Ejecutivo implicó un aumento de la alícuota, en contradicción con la voluntad legislativa, consistente en gravar en forma reducida el costo de las prestaciones a cargo de la amparista. Contra lo así resuelto, el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario que fue concedido, por la respectiva Cámara.

La Procuradora Fiscal Dra. Reiriz, dictamina con fecha 5 de noviembre de 1999, estimando que el recurso extraordinario fue correctamente concedido por el a quo, toda vez, que se halla en juego la inteligencia de normas federales (art. 80, 83, 99 inc. 3 de la Constitución Nacional; art. 1º, inc. m, de la ley 25.063 y arts. 1º, inc. f, y 7º del decreto 1517 del Poder Ejecutivo Nacional) y el resultado del litigio ha sido adverso a los derechos que la vencida funda en aquéllas (art. 14 incs. 1 y 3 de la ley 48). En cuanto al fondo de la cuestión, opinó que resulta evidente que la promulgación parcial examinada no puede realizarse en los términos del decreto 1517/98 sin menoscabo de su espíritu y unidad, dado que esa disposición no posee autonomía normativa respecto de la alícuota determinada por el Congreso y que el propio Poder Ejecutivo observó; en consecuencia, la sentencia apelada debería confirmarse.

b) Pretensión de la parte actora

Famyl S.A. promovió acción de amparo contra el Estado Nacional —Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públi-

cos— con el fin de obtener la inconstitucional de la ley 25.063, vetada y promulgada parcialmente por decreto 1517/98. Sostuvo la admisibilidad de la vía procesal intentada por no existir otros medios administrativos o judiciales idóneos para lograr el fin perseguido.

Del mismo modo, adujo que, a través del procedimiento descrito, se ha violado el principio de legalidad en materia tributaria (arts. 4º, 17 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional), sobre la cual no tiene competencia el Poder Ejecutivo Nacional, ni siquiera a través de los decretos de necesidad y urgencia, conforme a la expresa prohibición del inc. 3º del art. 99 de la Carta Magna.

Agregó, que no tiene otra opción que trasladar, el peso del tributo, al consumidor final —los afiliados— ya que, de lo contrario, tendría rentabilidad negativa y debería cesar en su operatoria, pero que, a su vez, dicho traslado determina una pérdida de afiliados o una modificación en la suscripción de planes hacia aquellos de más bajo costo, con disminución de sus utilidades.

c) Objeciones planteadas por la accionada

Disconforme, interpuso el recurso extraordinario. Sostiene su procedencia formal, toda vez que se discute en autos la inteligencia de normas federales, que la sentencia es arbitraria por no ser una derivación razonada del derecho vigente y que la materia discutida excede el mero interés de las partes, al afectar el de la comunidad toda, por lo que reviste gravedad institucional.

En cuanto a sus agravios contra el decisorio del “a quo”, expone, en primer lugar, que la actora no está legitimada, pues carece de un derecho subjetivo vulnerado, en la medida que traslada el IVA al consumidor final al cobrarlo junto con el precio del servicio, sin experimentar perjuicio alguno.

Por otra parte, afirma que el amparo no es la vía apta para ventilar la pretensión de la actora, cuya discusión —en todo caso— debe hacerse por la vía ordinaria, con amplitud de debate y prueba. Agrega que, en nuestro ordenamiento jurídico, los impuestos se deben pagar siempre, sin perjuicio de la posibilidad de repetirlos, si resultan mal determinados o son inconstitucionales, es decir, rige la regla del *solve et repete*.

En lo referente a la cuestión de fondo afirma, que el decreto 1517/98 es constitucional, y que con su dictado el Poder Ejecutivo no violó el principio de legalidad en materia tributaria, pues ejerció la atribución que le confiere el art. 80 de la Ley Fundamental.

El Estado Nacional recordó que el inc. m) del art. 1º de la ley 25.063 que dispone la alícuota del 10,5 %, no fue incorporado a la ley del IVA en el art. 28 que contiene las tasas diferenciadas, sino como artículo sin número a continuación del art. 54, en el Título IX de la ley, “Disposiciones Transitorias”. Es por ello, que si la intención del legislador hubiese sido gravar los servicios en cuestión con la alícuota 10,5 %, la hubiera incluido en el citado art. 28.

(5) Es que son dos institutos perfectamente diferenciables. V. GELLI, MARÍA ANGÉLICA, *Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada*, Buenos Aires, 2005, p. 768.

Entiende que la observación parcial realizada es fruto del ejercicio de facultades constitucionales y que, en modo alguno, rompe la unidad del proyecto de ley, ni altera su letra ni su espíritu, por lo que es innecesario el reenvío al Congreso.

d) Voto de la mayoría

El voto de la mayoría fue rubricado por los Dres: Julio S. Nazareno (según su voto), Eduardo Moliné O' Connor, Carlos Fayt, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi (según su voto), Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert. A continuación se transcribe los considerandos más importantes del mismo:

"... Que el recurso planteado es formalmente admisible en cuanto se dirige a cuestionar la decisión del *a quo* sobre aspectos sustancial de la controversia, pues la sentencia que se ha pronunciado en contra la validez de un acto de autoridad nacional (el decreto 1517/98), y se encuentra en discusión la inteligencia de cláusulas de la Constitución Nacional (arts. 80, 83 y 99) y de otras normas de carácter federal, como lo son la ley 25.063 y el citado decreto (incs. 1 y 3 del art. 14 de la ley 48)...", (consid. 6°).

"... Que en cambio, en lo atinente a los agravios reseñados en los párrafos segundo y tercero del considerando 5 —arbitrariedad y gravedad institucional—, la apelación planteada resulta inadmisible..." (consid. 7°).

"... Que, en efecto, en cuanto al reparo sobre la legitimación de la parte actora, resulta claro que ésta, en su calidad de contribuyente, se encuentra directamente afectada por las normas cuya validez constitucional ha impugnado, sin que la circunstancia de que el impuesto se encuentre concebido de modo tal de que su carga económica sea trasladable a terceros obste a tal conclusión. Esta última circunstancia podría eventualmente —en la hipótesis de que se compartiese el criterio establecido en el precedente de Fallos: 287:79 (luego abandonado en el caso registrado en Fallos: 297:500)— tener relevancia para determinar la procedencia de una acción de repetición por parte del contribuyente de *iure* que ha pagado al Fisco el impuesto cuya carga, a su vez, ha trasladado y percibido de terceros. En este supuesto —siempre a tenor del criterio establecido en el primero de tales precedentes, sobre cuya aceptación o rechazo resultaría inoficioso pronunciarse en la presente causa— podría eventualmente objetársele a aquél que estaría pretendiendo obtener del Estado —por vía de repetición— la compensación patrimonial que ha obtenido de terceros. Pero tal clase de razonamiento es manifiestamente inapropiada para un caso como el de autos, en el cual ningún obstáculo puede válidamente erigirse para negar a quien resultaría obligado frente al Fisco al pago del impuesto el derecho a impugnar judicialmente la validez de las normas que daría sustento a tal obligación..." (consid. 8°).

"... Que a la misma conclusión se llega en lo atinente al cuestionamiento de la procedencia de la vía de amparo toda vez que los argumentos de orden fáctico y procesal esgrimidos por el apelante no tienen entidad suficiente

para refutar los fundamentos dados por el *a quo* ni para dilatar el control de constitucionalidad que constituye la primera y principal misión del Tribunal (Conf. Fallos: 318:1154)... (consid. 9°).

"... Que en cuanto a la cuestión de fondo debatida en el *sub examine*, cabe señalar que lo relativo a los procesos de formación y sanción de las leyes, al constituir una atribución propia de los dos poderes constitucionalmente encargados de ello (el Congreso y el Poder Ejecutivo, según lo establecen los arts. 77 a 84 de la Constitución Nacional), resulta por regla general, ajeno a las facultades jurisdiccionales de los tribunales (Fallos: 53:420; 141:271; 143:131 y 210:855, entre otros). Empero, es doctrina de esta Corte que tal criterio reconoce excepción en los supuestos —como el suscitado en autos— en que se ha demostrado fehacientemente 'la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley' (Fallos: 256:556; 268:352 y doctrina de Fallos 311:2580, consids. 4° y 5°, entre otros)..." (consid. 10°).

"... Como adecuadamente lo señala la señora Procuradora Fiscal, dicha reforma recogió una sólida doctrina de esta Corte, expresada desde el pronunciamiento registrado en Fallos: 268:352, en el que se trató la cuestión de la validez de la promulgación parcial de un proyecto de ley y, correlativamente, si podían considerarse convertidos en ley los artículos no observados. Estableció entonces el Tribunal que cuando el proyecto constituye un todo inescindible, de modo que las normas no promulgadas no puedan separarse del texto legal sin detrimento de la unidad de éste, el Poder Ejecutivo no puede promulgar parcialmente el proyecto de ley sin invadir atribuciones propias del Congreso Nacional y sin asumir la calidad de legislador. Tal doctrina fue reiterada en los precedentes de Fallos 318:445, consid. 7° del voto de la mayoría y 9° de la disidencia del Juez Fayt, y 319:1479, consid. 3° del voto de la mayoría de la disidencia del Juez Petracchi. En esta última sentencia se afirmó que aquella doctrina 'se ha visto confirmada por el texto constitucional sancionado en 1994'..." (consid. 11°).

"... Que, admitida la constitucionalidad del veto parcial, la cuestión por resolver remite a determinar si, observada por el Poder Ejecutivo la norma que redujo la alícuota del impuesto a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica (inc. m. del art. 1° del proyecto sancionado por el Congreso), con el obvio propósito de que quedasen sujetos a la tasa fijada por el primer párrafo del art. 28 de la ley del tributo, pudo promulgar válidamente la disposición que eliminó la exención de que gozaban los sistemas denominados de medicina prepaga (inc. e, punto 4 del art. 1° del citado proyecto). A la luz de los preceptos constitucionales citados, y según la doctrina a la que se hizo referencia, ello conduce a determinar si la disposición promulgada tiene autonomía normativa respecto de la primera y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. A tal efecto es pertinente destacar, en coincidencia con la opinión de la Señora Procuradora Fiscal, que dada la multiplicidad de materias sobre las que trata la ley 25.063 —y la consiguiente relativa independencia de las normas respectivas— no cabe efectuar ese juicio con relación a todas ellas, sino que él debe circunscribirse a las que conciernen al tratamiento en el impuesto al

valor agregado de las empresas denominadas de 'medicina prepaga', de manera que tal examen queda circunscripto a las disposiciones a las que se ha referencia precedentemente..." (consid. 12).

"... Que, sentado lo anterior, resulta evidente que la promulgación parcial, en el punto indicado, no se ajusta a lo prescripto por el art. 80 de la Constitución Nacional. En efecto, el Congreso Nacional aprobó dos normas por las que fijó el tratamiento en el impuesto al valor agregado de las empresas de medicina prepaga: por la primera, eliminó la exención establecida por la ley entonces vigente, y por la segunda, dispuso que la alícuota del impuesto sería la mitad de la prevista con carácter general por la ley del tributo. Es manifiesta la unidad existente entre ambas, la cual se encuentra claramente corroborada por el trámite parlamentario, que pone en evidencia la interrelación de una con la otra, y aunque ése fue el medio que el Congreso consideró adecuado para, por una parte, incrementar la recaudación sujetando al tributo una prestación que hasta entonces se hallaba exenta, pero al mismo tiempo, atenuando el nivel de la imposición a fin de no encarecer, más allá de lo que estimó aceptable, un servicio de interés social..." (consid. 13).

"... Que, en síntesis, los incisos e, punto 4, y m del art. 1° del proyecto constituyen un todo inescindible motivo por el cual al haber vetado el Poder Ejecutivo al segundo de ellos (el inc. m), la promulgación parcial dispuesta mediante el art. 7° del decreto 1517/98, en cuanto incluyó al primero (inc. e punto 4), es constitucionalmente inválida porque no se ajusta a lo prescripto por el art. 80 de la Ley Fundamental. En tales condiciones, el citado inc. e punto 4, no es estrictamente una norma jurídica, de lo que se sigue que el Fisco Nacional no podría fundar derechos en una ley inexistente (Fallos: 268:352, cons. 6 *in fine*, y doctrina de Fallos: 189:156, 163 y 268:352)..." (consid. 15).

"... Que habida cuenta que las sentencias del Tribunal deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos: 298:33; 304:1649; 312:555, entre muchos otros), corresponde examinar la ulterior actuación del Congreso, en orden a lo establecido por el art. 83 de la Constitución Nacional..."

"... En efecto, según surge de la nota 242/99 dirigida por el Senado al señor presidente de la Nación (publicada en el Boletín Oficial del 2 de agosto de 1999), la Cámara de Diputados —atento a la observación que el Poder Ejecutivo efectuó respecto de ciertas normas del proyecto de ley registrado bajo el número 25.063— insistió en su anterior sanción de aquéllas, incluyendo tal insistencia al inciso m del art. 1° del proyecto (que fijaba la alícuota reducida en el IVA para los sistemas de medicina prepaga). Por su parte, el Senado, si bien coincidió con la cámara baja en la insistencia respecto de determinadas normas, en lo que resulta relevante para el caso *sub examine*, rechazó expresamente la insistencia en lo concerniente al citado inc. m del art. 1°."

"De ese modo, se advierte con nitidez que no medió, entre ambas cámaras, la exigida confluencia de voluntades con relación al citado inciso a fin de

considerarlo como 'ley' en los términos del mencionado art. 83 de la Constitución Nacional. Por el contrario, tal diferencia de criterios sobre el punto determina, según lo prescribe la última parte de ese artículo, que 'el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año'..." (consid. 17).

"... Que, en síntesis, el Poder Ejecutivo observó válidamente el inc. m del art. 1° y, por lo tanto, esa disposición no se convirtió en ley. La discrepancia entre las Cámaras del Congreso en cuanto a la insistencia sobre ese punto obstó a que tal efecto se produjese del modo previsto por el art. 83 de la Constitución Nacional. En tales condiciones, y según ya ha sido expuesto, resulta inválida la promulgación de una norma inescindiblemente vinculada a ella, como lo es la del inc. e. 4 del mismo artículo, por lo cual tampoco esta última constituye ley en la que pueden fundarse derechos del Fisco Nacional; por el contrario, la consecuencia de lo expuesto es que se ha mantenido en vigor el último párrafo del punto 7 del inc. h del primer párrafo del art. 7° de la ley del gravamen y, por consiguiente, la exención que beneficia a la actora, en los términos establecidos con anterioridad a la ley 25.063 sin perjuicio de lo que resulte, para hechos posteriores a la vigencia de la ley 25.239, de lo prescripto por el inc. i de su art. 2°, norma respecto de la cual esta sentencia no implica pronunciamiento alguno, y sobre la que no corresponde decidir a esta Corte ya que su examen resultaría ajeno al objeto de este pleito, habida cuenta que la aplicación del impuesto al valor agregado a la empresa actora ha sido cuestionada sobre la base de las objeciones formuladas a la ley 25.063".

"En lo atinente a la mencionada ley 25.239, sólo cabe dejar establecido que su art. 27 no puede tener el efecto de sanear el vicio que afecta a la ley 25.063 en el punto antes mencionado —pues al respecto el Congreso finalizó su actividad posible, de acuerdo con lo que ordena la Constitución Nacional— ni tampoco la de establecer la aplicación del impuesto a hechos acaecidos y perfeccionados con anterioridad, debido a que, además de que la retroactividad no es aceptable, ella tampoco resulta del texto legal..." (consid. 19).

"Por ello, y de conformidad con las conclusiones del dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario en los términos que resultan de los considerandos 6° a 9°, y se confirma la sentencia apelada con el alcance expresado en la presente. Con costas. Notifíquese y devuélvase".

e) Glosa doctrinaria

En primer lugar, a modo introductorio podemos decir, que el análisis de este instituto por parte del Poder Judicial de la Nación, no se deberá en ningún caso centrar en el mérito o conveniencia de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni del Congreso de la Nación, ya que, entraríamos en el área denominada no justiciable, por ser una decisión de carácter político-económico que debe discutirse y analizarse por los mismos poderes políticos; sin embargo, resulta enteramente justiciable a través del examen de razonabilidad, tanto el veto parcial como la mentada promulgación parcial,

porque como ya dijimos son ambas indispensables para su ejercicio constitucional.

Si bien la cuestión político-económica, no es un tema de la jurisprudencia en análisis, es bueno destacar al respecto, que existe una clara pretensión de justificar la aplicación del IVA a la salud basándose en el concepto de *igualdad y equidad tributaria*, sosteniendo que el impuesto es más justo cuando se lo generaliza a todos los sectores.

Sin embargo, es necesario inquirir en el verdadero origen de la exención que existe en la Argentina para el sector salud desde el origen del IVA. A nuestro criterio, dicha exención está justificada sobre la teoría de que todo sistema tributario debe ser justo y equitativo y que los impuestos indirectos, como el IVA, tienen un fuerte efecto regresivo sobre los consumidores de bajos recursos, que gastan todo su ingreso en la simple subsistencia.

Por esta razón el pan, la leche, el agua, la venta de medicamentos en farmacias, la educación privada y los sistemas de cobertura de salud de obras sociales y medicina prepaga están exenta del IVA en nuestra legislación.

Los servicios médicos prestados por obras sociales y medicina prepaga, cumplen una función social supletoria de la del Estado, ayudando al mismo a asegurar la salud de la población.

En todas las democracias del mundo son funciones indelegables del Estado *asegurar y promover la seguridad, la justicia, la educación y la salud*.

Por esta razón, extender el IVA a la salud basándose en una aplicación falaz del concepto de equidad tributaria o cualquier otro fundamento, implica atentar lisa y llanamente contra los derechos y garantías de la población. Con esa misma premisa se podría extender el IVA a sueldos, jubilaciones y pensiones.

Ahora bien, en cuanto al examen de razonabilidad del veto parcial y la promulgación parcial del fallo en cuestión, deberá en primer lugar determinarse si la disposición promulgada tiene autonomía normativa respecto de la primera y en segundo término, si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. A tal efecto, es pertinente destacar, en coincidencia con la opinión de la Señora Procuradora Fiscal y del voto del Dr. Julio S. Nazareno, que dada la multiplicidad de materias sobre las que trata la ley 25.063 —y la consiguiente relativa independencia de las normas en cuestión— no cabe efectuar ese juicio con relación a todas ellas, sino que él debe circunscribirse a las que concierne al tratamiento en el impuesto al valor agregado de las empresas denominadas de “medicina prepaga”.

En “Famyl S.A.” la cuestión debatida en el caso, no se centraba en el veto parcial que resulta ajustado a las pautas constitucionales, sino en la promulgación parcial.

La constitucionalidad del veto parcial sólo depende de la oportunidad de su emisión. En cambio, la promulgación parcial sólo procede si se dan las dos requisitorias ya enunciadas.

La situación consumada es la siguiente: a) la ley derogó exenciones; b) a contribuyentes que se hallaban exceptuados les aplicó un impuesto menor que el común del 21 %; c) el Poder Ejecutivo vetó la norma referida en el anterior inc. b, pero no vetó —sino que promulgó— la que deroga la exención.

El Congreso cuando controla la promulgación o el Poder Judicial cuando hace lo propio, examinando la validez constitucional de aquella deben determinar cuál es el espíritu de la ley y de qué unidad se trata. Desde luego, que el problema es más sencillo de resolver para el Poder Legislativo quien, se supone, tiene en claro qué quiso hacer con el proyecto que sancionó.

En cuanto a los motivos, la flagrante inconstitucionalidad del caso “Famyl S.A.” se funda en varias razones. Veamos brevemente cuáles son:

1. La primera razón, desde nuestro punto de vista, lleva a recordar que el art. 80 en la redacción que le dio la reforma constitucional de 1994 sienta como principio general el de que los proyectos de ley desechados (vetados) parcialmente por el Poder Ejecutivo no pueden aprobarse en la parte restante; como excepción, la norma dice luego que, sin embargo las partes no observadas solamente podrán promulgarse si tienen autonomía normativa y si su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso (6). En este caso —continúa el art. 80— será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia, con lo que se hace remisión al art. 99, inc. 3°, párrafo cuarto.

Ello así, corresponde examinar la ulterior actuación del Congreso, en orden a lo establecido por el art. 83 de la Constitución Nacional.

En efecto, según la nota 242/99 dirigida por el Senado al señor Presidente de la Nación, surge que la Cámara de Diputados insistió en su anterior sanción de aquellas, incluyendo tal insistencia al inciso m) del art. 1° del proyecto. Por su parte, el Senado, si bien coincidió con la cámara baja en la insistencia respecto de determinadas normas, en lo que resulta relevante para el caso, rechazó expresamente la insistencia en lo concerniente al citado inc. m) del art. 1°.

De ese modo, se advierte con nitidez que no medió, entre ambas cámaras, la exigida confluencia de voluntades con relación al citado inciso a fin de considerarlo como “ley” en los términos del mencionado art. 83 de la Constitución Nacional. Por el contrario, tal diferencia de criterios sobre el punto determina, según lo prescribe la última parte de ese artículo, que “el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. En consecuencia, ninguna de ambas cámaras ni siquiera se ha acercado a la alícuota fijada por el decreto 1517/98, es decir, no encontró la promulgación parcial aprobación alguna por parte del Parlamento Nacional, resultando dicho decreto como un manifiesto alterador del espíritu del proyecto normativo.

(6) Debe reconocerse que estos parámetros son bastante “difusos”. V. ONAINDIA, JOSÉ MIGUEL, *Instituciones de Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2004, p. 161.

posibles un veto parcial y una promulgación parcial de la parte no vetada, el resultado se tiene que limitar a no aplicar el artículo vetado, dejando intacta la situación existente con anterioridad a la norma vetada, pero no dando origen a una situación nueva. Pues bien, en el caso comentado no se respeta esa pauta, porque al vetarse la norma que a los antes exentos les aplicaba un porcentaje inferior al general del 21 %, se los da por incluidos entre los contribuyentes de ese 21 %. Y acá convergen dos cosas: una, que en realidad ese tributo proviene de una decisión del Poder Ejecutivo y no del Congreso, con lo que el Ejecutivo transgrede el principio de legalidad, elemental de la Constitución que prohíbe crear impuestos por decreto cuando exige ley previa; otra, que se crea una situación nueva al margen de la ley que ha sido objeto de veto parcial y de promulgación parcial, ya que ni se mantiene la exención ni se respeta la voluntad del Congreso que, en la norma vetada, quiso imponer una contribución menor.

3. La Corte, teniendo en cuenta que la finalidad del legislador al eliminar la exención del pago del IVA para las empresas de medicina prepaga y establecer una alícuota reducida, procuró incrementar la recaudación aplicando el tributo a una prestación que hasta entonces se hallaba exenta, pero atenuando el nivel de imposición a fin de no encarecer un servicio de interés social, sostuvo, por el voto de siete de sus nueve miembros, que la promulgación parcial citada no se ajusta a lo dispuesto por el art. 80 de la CN. Atento que los incs. e), punto 4 y m) del art. 1º del proyecto constituyen un todo inescindible, motivo por el cual al haber vetado el PEN al segundo de ellos, inc. m), la promulgación parcial dispuesta mediante el art. 7º del dec. 1517/98 resulta constitucionalmente inválida. Ergo, el citado inc. e), punto 4 no es estrictamente una norma jurídica, de lo que se sigue que el Fisco Nacional no podría fundar derechos en una ley inexistente.

Finalmente, el voto de la mayoría, dejó establecido que la ley 25.239, no puede tener el efecto de sanear el vicio que afecta a la ley 25.063 en el punto antes mencionado, ni tampoco la de establecer la aplicación del impuesto a hechos acaecidos y perfeccionados con anterioridad, debido a que, además de que la retroactividad no es aceptable, ella tampoco surge del texto legal.

En cuanto a la disidencia del Dr. Vázquez, no compartimos lo expresado en el considerando 16 donde se trata de establecer una armonía de criterios implícitos entre ambos poderes del Estado —Poder Ejecutivo y Poder Legislativo— como basamento hacia la constitucionalidad de la promulgación parcial, pero es de destacar al respecto, que el voto en disidencia se encuentra en franca oposición a lo dispuesto por el art. 82 de la Constitución Nacional, es decir, que tanto la falta de previsión como la voluntad explícita del Congreso de la Nación no se presume, ya que, justamente dicha normativa trata de algún modo de frenar estas facultades legislativas tan cuestionadas que fueron otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional por la reforma de 1994.

Para concluir con todo lo expuesto, diremos que los doctrinarios del estado de derecho hicieron hincapié permanente, en el mantenimiento de la premisa que hace al principio de la división de los poderes constituidos, como base de la legitimidad de todo gobierno.

En ese orden de ideas, se hizo especial ahínco en la reserva de exclusividad, para el Legislativo, de la capacidad para legislar. Esto debe verse en la tenaz defensa de esa exclusividad, que se opuso y que todavía hasta antes de la reforma se oponía permanentemente a todo tipo de delegación legislativa, al miedo concreto y real, que por el camino de esta, se cambie el final del Estado de derecho, al dar la capacidad de concentración de poderes en el Ejecutivo.

Para el legislativo la zona de reserva consiste en hacer la ley, ya sea fijando los lineamientos esenciales (ley bases) o especificando mayores detalles (ley común); para el ejecutivo estriba en aplicar la ley y para el judicial en interpretarla.

Es por ello, que el art. 29 de la Constitución Nacional prohíbe el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo e impone la pena correspondiente a los infames traidores a la Patria a los legisladores que lo autoricen. Esta prohibición está reiterada en el comienzo de los arts. 76 y 99, inc. 3. Mientras que el art. 80 prohíbe como principio general la promulgación parcial de leyes.

Ante esos principios generales las excepciones contempladas en las normas que autorizan las delegaciones legislativas, los decretos de necesidad y urgencia y la promulgación parcial de leyes, deben ser de interpretación restrictiva existiendo materias que son competencia exclusiva del Congreso y con relación a las cuales no pueden hacerse delegaciones legislativas ni dictarse decretos de necesidad y urgencia.

Los principios generales de nuestra Constitución son coherentes con el sistema presidencialista que establece la división de poderes y toda alteración de esa división produce un desequilibrio que afecta el sistema constitucional. Ello ocurre con el ejercicio de funciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo si ese ejercicio no está limitado a las excepciones estrictas establecidas por la Constitución en los casos expresamente autorizados. Esta línea de pensamiento es afín a aquella que considera que el Congreso debe ser sólo "reactivo" a los deseos presidenciales (7).

El caso "Famyl S.A." ilustra acerca de cómo una atribución excepcional es utilizada para imponer el criterio del Poder Ejecutivo por sobre la voluntad del Congreso alterando tanto su espíritu como la unidad normativa, máxime en materias, como la tributaria, en las cuales el presidente tiene prohibido

(7) V. CARNOTA, WALTER F., *Instituciones de Derecho Público*, Buenos Aires, 2005, p. 74.

soluciones por medio no republicanos.

Nos enseña M. Ghandi; que "...los medios pueden compararse a una semilla y el fin a un árbol. De la calidad de la semilla depende el árbol; de la calidad de los medios depende el fin de la obra. No es posible llegar a fines lícitos por medios ilícitos..."

CAPITULO II.5

DELEGACIÓN LEGISLATIVA

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Naturaleza jurídica. — 3. Concepto y evolución. — 4. Los cambios en el sistema político. — 5. Reforma constitucional de 1994. — 6. El control parlamentario. — 7. Precisiones sobre los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre delegación legislativa. — 8. Recapitulación.

1. INTRODUCCIÓN

Como sostuvimos en el capítulo anterior, el principio general es que la facultad de legislar es "zona de reserva" del Congreso y en consecuencia, por el principio de división de poderes, el ejecutivo tiene prohibido legislar.

A esta prohibición general implícita que surge de la forma de gobierno y que podemos definirla como genérica, la Constitución reformada le agrega tres prohibiciones específicas, sobre las que, antes de 1994, no existía doctrina pacífica sobre su constitucionalidad.

Estas tres prohibiciones abarcan: la delegación legislativa (art. 76), los decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inc. 3) y la promulgación parcial de normas (art. 80).

La delegación legislativa no tenía rango constitucional antes de 1994, pero su recepción jurisprudencial desembocó en la creación del actual art. 76. Esta circunstancia es producto de una larga evolución ocurrida en el marco de la realidad política argentina.

Es interesante investigar cómo nace esta atribución. En un principio, como el Congreso dictaba la norma "fundante", se la asimiló a la potestad reglamentaria del art. 99, inc. 2, pero ensanchada. Con el tiempo, las facultades delegadas tomaron autonomía propia. Si bien en ambos casos existía una situación de partida similar, la ley del Congreso, las potestades en un caso y en otro, diferían completamente.

¿En qué consiste la delegación legislativa? ¿Cuál es el alcance de esta facultad y quién va a realizar su control?

156

El estudio de la naturaleza jurídica apunta principalmente a encontrar la esencia. El Diccionario de la Real Academia Española define la esencia como "lo permanente e invariable en las cosas, lo que el ser es" y como "lo más puro, más fino y acendrado de una cosa, lo indispensable; ser condición inseparable de ella".

Desde esa definición podemos decir que el instituto de la delegación legislativa está directamente emparentado con la actividad de legislar. Esta ha sido siempre, en nuestro ordenamiento jurídico, una atribución propia del Congreso. Sin embargo, esta regla general que ponía únicamente en cabeza de este órgano esta facultad, fue perdiendo con el tiempo su rigidez hasta desvirtuarse y llegar, hoy en día, a convertir la excepción en una regla.

En la búsqueda de desentrañar la esencia del acto de legislar, la primera idea que nos viene en mente, es la facultad del Congreso de dictar leyes, es decir, normas con alcance general. Pero esta definición no alcanza, ya que como bien plantea Bidart Campos (1), "todos están de acuerdo en que no basta la forma de ley en un acto del Congreso para reconocer naturaleza de ley material a ese acto".

Las teorías se dividen al intentar definir la naturaleza de la ley. Para una corriente, *leyes* toda norma de carácter general y obligatorio, lo que incluiría también los reglamentos del Poder Ejecutivo y hasta los fallos plenarios. Para la otra, *ley* es solamente la creación normativa que da origen a un derecho nuevo u originario, acogiéndose el autor citado a esta última postura.

Antes de la reforma de 1994, Bidart Campos señalaba que "la ley, la administración y la jurisdicción crean derecho. Pero solo la ley crea derecho novísimo; las otras dos crean derecho condicionado o determinado en su margen y contenido". Hay que tener en cuenta que él como varios otros prestigiosos constitucionalistas, consideraban inconstitucional el dictado de los decretos de necesidad y urgencia y la promulgación parcial de normas.

3. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN

Si se quiere, el siglo XX fue "la centuria del Poder Ejecutivo" (2), allí donde este órgano vio acrecentada sus funciones, fruto del llamado "Estado de Bienestar" y de nuevos cometidos que se asignaba al poder público. Ese fenómeno impactó de manera peculiar en Latinoamérica, dando lugar entre otros factores a la aparición de las "democracias delegativas" en la conocida terminología de O' Donnell (3).

(1) *Manual de la Constitución reformada*, Buenos Aires, 1997, t. III.

(2) V. BIDART CAMPOS, GERMÁN J. y CARNOTA, WALTER F., *Derecho Constitucional Comparado*, Buenos Aires, 2000, t. II, p. 47.

(3) V. BIDART CAMPOS, GERMÁN J. y CARNOTA, WALTER F., ob. y t. cit., p. 42, nota 3.

estructuras gubernativas en donde los diálogos entre Ejecutivo y Legislatura son más fluidos y permanentes, es decir, en las formas de gobierno de cariz parlamentario. Empero, aún en los Estados Unidos se admite, pese a que en el país del Norte no existe estampada en el texto constitucional la potestad reglamentaria, como acontece entre nosotros en el art. 99, inc. 2, fruto de la Constitución de Cádiz de 1812.

4. LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA POLÍTICO

Antes de la reforma, el diagnóstico marcaba que la ciencia política y el derecho constitucional del poder habían sufrido una mutación indiscutible, que era el desplazamiento de facultades parlamentarias hacia el Poder Ejecutivo.

Paradójicamente, este viraje comienza a producirse con el desarrollo y complejidad que va adquiriendo la sociedad democrática, en la que la figura del Poder Ejecutivo empieza a perfilarse como la más apta para resolver con rapidez y aparente eficacia los conflictos que aquejan a los distintos sectores de la sociedad.

La evolución de la democracia se caracteriza justamente por ir ampliando la gama de derechos de los habitantes y en consecuencia, en la obligación de atender la demanda de sectores postergados que con mayor conocimiento y conciencia de los mismos, solicitan su cumplimiento.

Esta tendencia se manifiesta en el ámbito mundial y es tan fuerte que no escapan a ella los sistemas parlamentaristas, en los que, generalmente, el ejecutivo depende de la confianza del parlamento para mantenerse en el poder. Aún en estos casos ha existido el viraje de timón que recae cada vez más en el ejecutivo.

Si bien la tendencia es universal, en cada sistema la repercusión será distinta, según las características particulares de sus componentes.

Esta inversión de roles no es menor en el estudio de las formas de gobierno, ya que tiene como primera y principal consecuencia, un avance sobre la clásica división de poderes, principio republicano por excelencia. El cambio no es azaroso sino que puede ser atribuido, no sólo a la evolución de la democracia, sino a la naturaleza misma de cada poder y a la cultura del sistema político argentino.

En efecto, basta analizar la estructura y forma de funcionar de nuestros órganos políticos para comprender cómo han respondido a las nuevas necesidades.

Por un lado, el Congreso compuesto por dos cámaras, conformada cada una por un elevado número de miembros. Esta composición no es caprichosa sino que es necesaria para lograr la representatividad democrática. Pero, la

157

nes, que exige tiempo y debate para que se configure la voluntad colegiada.

Es lógico que así sea pues el resultado garantiza, en principio, que la norma sancionada goce de la mayor representación posible. En síntesis, la ley es más lenta pero es más valiosa, porque su contenido es pluralista y representativo.

En cambio, el Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal, a pesar de estar acompañado por el gabinete de ministros y el personal subordinado. Por otra parte, la Constitución le otorga la titularidad de la administración general del país, al designarlo como responsable político, como ya vimos *supra*. Esta misión de llevar adelante las políticas de gobierno lo obliga a un permanente dinamismo y a tener que responder instantáneamente para mantenerse en el poder.

Esta diferencia de estructura y de función entre los dos poderes ha determinado el tablero de juego en el que ambos se desenvuelven.

Surge entonces el viejo dilema del "huevo y la gallina". ¿Cuál es la causa y cuál la consecuencia?

¿El avance evidente del presidencialismo es generado por un sistema que necesita una figura de un presidente fuerte, carismático y único representante del poder o a la inversa, la sociedad necesita de esta figura porque el régimen en sí genera esta necesidad de "hiperpresidencialismo"?

La respuesta no es lineal y creemos que debe formularse en este doble sentido. Nuestros orígenes históricos nos remontan a un poder ejecutivo monárquico, ejercido por el virrey, que era representante del rey de España en las colonias. El virrey, al igual que el rey, concentraba para sí los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El absolutismo monárquico español está en el germen de nuestros poderes constitucionales.

Al independizarnos de España, surgió un gran debate sobre la forma de gobierno que convenía adoptar para nuestro país, en el que venció el modelo presidencialista norteamericano.

Los antecedentes que forjaron nuestra Constitución y la ideología alberdiana que la inspiraron, creían firmemente en un Poder Ejecutivo fuerte, como así también en un Estado federal fuerte. Muestra de ello, la hallamos, por ejemplo, en la terminología utilizada en el art. 99, que existe hasta el día de hoy y cataloga al Presidente como "jefe supremo de la Nación". Encontramos en este término más resabios de la figura de un monarca que de un funcionario republicano sometido al imperio de la ley.

No sólo estamos determinados por el sello de nuestra Historia. Entre otras causas que fueron inclinando la balanza en desmedro de los otros poderes, Bidart Campos cita la propia dinámica de nuestro federalismo, que fue acentuando las competencias del gobierno federal.

racionalidad con la que podían resolverse, con el fin de domar provincias opositoras (4).

La emergencia ha sido otro comodín por excelencia para acrecentar facultades. Somos un país en el que la normalidad es excepción, y en el que la excusa de la emergencia ha servido para cometer las peores atrocidades (5).

También se puede analizar la responsabilidad del Congreso quién al dictar legislación con estándares demasiado genéricos, deja amplio margen de reglamentación a cargo del ejecutivo.

Como podemos comprobar existe un permanente interjuego entre la realidad política y la normativa constitucional. El sistema político exige ese desplazamiento. La dinámica constitucional puede ser asimilada a las leyes de la física. Basta la modificación de un solo vector para que cambie todo el sistema de fuerzas.

5. REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994

La reforma constitucional de 1994 recogió la figura de la delegación legislativa, incluso llamándola con ese nombre, en el art. 76 del plexo de base, que dice:

"Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa".

El art. 76 establece el marco en el que la delegación será válida. Su técnica legislativa es criticable dado que comienza enunciando una prohibición tajante de delegación, que aparenta ser la regla y a renglón seguido, enuncia excepciones que por su vaguedad y amplitud, hacen caer por completo la referida prohibición.

Se establecen también condiciones espaciales y temporales. La delegación debe ejercerse dentro de las bases que el Congreso establezca. Esto implica que debe existir necesariamente una ley previa dictada por el órgano delegante, con una clara política legislativa fijada con anterioridad delimitando

(4) Manual de la Constitución reformada, Buenos Aires, 1997, t. III.

(5) Es el caso de los gobiernos de facto, con disolución del Congreso. Especialmente, el Proceso de Reorganización Nacional.

didos.

La práctica ha demostrado que casi no hay cuestión que pueda quedar afuera de los requisitos establecidos por el artículo, que son "materias determinadas de administración y de emergencia pública", teniendo en cuenta que la función propia del ejecutivo es administrar y que se trata de un país que vive en emergencia. Cualquier argumento bien defendido ha ingresado en estas categorías.

Cabe destacar que la norma bajo examen no es un prodigio de claridad conceptual, y ofrece una textura abierta, como muchas otras oriundas de la revisión de 1994. Los contornos tan imprecisos son propios de los intentos por mitigar el excesivo presidencialismo imperante en ese momento, y la dinámica de ese poder para esquivar cualquier freno. Los consensos fueron mínimos y las dificultades muchas.

Ello se advierte palmariamente en esta redacción alambicada y confusa. Empieza con lo que aparentemente sería una regla prohibitiva de la delegación legislativa que sucesiva —y de manera creciente— la Corte Suprema de Justicia había convalidado con los contornos fijados en los casos "Delfino" (Fallos: 148:430), "Mouviel" (Fallos: 237:636) y sobre todo "Cocchia" (Fallos: 316:2624) (6).

Las excepciones consagradas a esa presunta prohibición (de similar factura formal a la consagrada en el tercer inciso del art. 99 respecto de los decretos de necesidad y urgencia) son sumamente latas, y facilitan múltiples interpretaciones al operador del sistema. Resulta francamente difícil perfilar la materia administrativa en sí (7), y ni qué decir de lo relativo a las sempiternas situaciones de emergencias públicas, que han generado "más emergencia e inseguridad" (8).

El propósito de estas salvedades es tornar más flexible si se quiere a la división de poderes, abasteciendo al Ejecutivo de armas y herramientas rápidas para una mejor gobernabilidad del sistema en su conjunto. Hasta allí la argumentación formal en su defensa. Lamentablemente, su notoria amplitud las hace proclives a tergiversaciones y a abusos, transvasando la facultad legisferante al órgano Ejecutivo.

(6) Una famosa frase de la sentencia "Delfino" indica que: "Existe una distinción fundamental entre el poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido aun en aquéllos países en que, como en los Estados Unidos de América, el poder reglamentario del Poder Ejecutivo se halla fuera de la letra de la Constitución".

(7) V. GELLI, MARÍA ANGÉLICA, *Constitución de la Nación Argentina*, Buenos Aires, 2005, p. 751.

(8) Así lo manifiesta el juez Ricardo Lorenzetti, en su ampliación de fundamentos en autos "Massa, Juan Agustín", sentencia del 27/12/2006.

La regla que la norma admite lo que jurídicamente se ha dado en denominar "delegación impropia", vedando por el contrario la "delegación propia". La regla, empero, no es explícita en su recepción de esa parte o de la totalidad de la doctrina sentada en "Delfino", como que tampoco es notorio el deslinde conceptual entre una y otra delegación, pese a su reiterada recepción en sede doctrinaria.

Un planteo interesante del tema lo realiza Alberto Bianchi (9), quien sistematiza la problemática de la institución bajo análisis en cuatro ejes temáticos, a saber:

A) Una primera duda a despejar estriba en determinar qué tipo de delegación se encuentra ahora prohibida por la directiva del art. 76 citado. Resulta evidente que se prohíbe como regla toda clase de delegación, si nos atenemos a la literalidad amplia del enunciado normativo.

B) Respecto de qué órgano se ve beneficiado con la delegación, coincidimos con el referido autor que a partir de 1994 sólo el Poder Ejecutivo podría recibir estas facultades provenientes del Congreso.

C) Asimismo, concordamos en que la excepción relativa a la materia de "administración" es muy abierta, y corre el serio riesgo de establecer en la praxis una nueva regla a favor de la delegación.

D) Otro tanto ocurre con la emergencia, máxime cuando también hay otro instrumento como son los decretos de necesidad y urgencia, previstos por el art. 99 inc. 3 CN, que también juegan para conjurar una situación crítica. De hecho, los decretos relativos a la "pesificación" usaron ambos institutos como fundamento, lo cual había sido descalificado por la Corte Suprema en el caso "Provincia de San Luis" de marzo de 2003, y que luego el Alto Tribunal revirtiese en "Bustos" (2004) y en "Massa" (2006).

6. EL CONTROL PARLAMENTARIO

El art. 100 inc. 12 de la Constitución, al referirse a las atribuciones del Jefe de Gabinete, le encarga el refrendo de los decretos delegados, "los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente". Esa Comisión no es una más con las que cuentan las Cámaras legislativas en virtud de sus normas reglamentarias, sino que ha sido creada directamente por la Constitución para la supervisión del accionar en materia de decretos delegados y de decretos de necesidad y urgencia. Su reglamentación se encuentra en la ley 26.122, como ya fue adelantado.

(9) V. BIANCHI, ALBERTO B., "La delegación legislativa luego de la reforma constitucional de 1994", en "Boletín Informativo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional", diciembre de 1996, p. 6.; CARNOTA, WALTER F., *Instituciones de Derecho Público*, Buenos Aires, 2005, ps. 83 y sigtes.

159

EMPLEADOS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SOBRE DELEGACIÓN LEGISLATIVA

Como ya se dijo, la línea trazada por el derecho judicial de nuestra Corte comienza con el fallo "Delfino". Allí el Alto Tribunal empieza a delimitar la figura bajo examen, al efectuar el mencionado distingo entre la transferencia de facultades de un poder a otro (lo cual no está permitido), y la precisión reglamentaria que requieren los derechos.

A tales efectos, y con cita de jurisprudencia norteamericana, se refieren las dificultades en delimitar con exactitud las atribuciones reglamentarias del Congreso y del Presidente. Dentro de este orden de ideas, se autoriza al Ejecutivo a regular los pormenores de la ley, mientras la política legislativa resulte clara, lo cual de ningún modo equivale a instaurar la ley misma.

"Cocchia" es construido con mucha más latitud, desde el momento en que la mayoría del Alto Tribunal no discierne límites concretos a la actividad reglamentaria del Ejecutivo. Por el contrario, el voto disidente en este polémico fallo, plantea la problemática de la "confusión de poderes", máxime en un sistema presidencialista como el nuestro.

Sobre el punto, se ha expresado que: "En nuestro país, el análisis de la delegación legislativa sufre una distorsión debido a la adopción, dentro de un sistema de división de poderes, de instituciones de sistemas de confusión de poderes. Es decir, que en un sistema de gobierno presidencial se han introducido normas administrativas importadas de los sistemas parlamentarios. Se ha querido explicar esta situación como la de tener un régimen constitucional de origen norteamericano y un sistema administrativo de origen francés, lo que ha sido llamado las dos caras de Jano" (10).

En definitiva, como balance de este análisis jurisprudencial, debemos coincidir con María Angélica Gelli cuando afirma: "Como surge de 'Delfino' la voluntad del Congreso se había manifestado en una ley que integró el Poder Ejecutivo al dictar el Reglamento del Puerto de la Capital Federal. En cambio, en 'Cocchia', la Corte Suprema halló una clara política legislativa del Congreso en lo que denominó bloque de legalidad, integrado por las leyes 23.696 de emergencia económica, en especial uno de sus artículos, la ley 24.094 de puertos y el Tratado de Asunción que creó el Mercosur... ¿cuál es la delegación que admiten las dos excepciones mencionadas en el art. 76? Sin duda la impropia, siempre que las bases de delegación estén establecidas... las bases de delegación implican algo menos que una clara política legislativa y algo más que el bloque de legalidad" (11).

En el fallo "Cafés La Virginia S.A." (Fallos: 320:1166) la Corte consideró irrelevante el estudio de la validez de la delegación contenida en el art. 665

(10) V. SOLA, JUAN V., *Derecho Constitucional*, Buenos Aires, 2006, p. 740.

(11) V. GELLI, MARÍA ANGÉLICA, *Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada*, ob. cit., ps. 748, 749 y 750.

des que delega el legislador deberán ejercerse respetando los convenios internacionales vigentes" lo que no ocurrió en el caso.

Por otra parte, la pirámide jurídica luego de la reforma del año 1994 contiene un orden normativo que pone a los tratados internacionales en un rango superior a las leyes.

Por ello, la supremacía del tratado por sobre la ley interna es doble: por un lado, genera un incumplimiento en el orden interno por violación al principio de supremacía y, por el otro, pone al Estado en un incumplimiento frente a la comunidad internacional (art. 31 CN y art. 27 Convención de Viena).

Resulta de máximo interés el estudio de los perfiles de este instituto analizado en los distintos votos del caso más resonante en el ámbito jurisprudencial de estos últimos tiempos. Se trata de la sentencia "Pcia. de San Luis c. PEN s/ amparo" dictado el 5 de marzo de 2003 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 326:417).

Trabada la litis en estos términos, el fallo de la Corte fue dictado por una mayoría alcanzada con distintos votos. Por un lado, votó el Dr. Nazareno; por otro, votaron Moliné O' Connor y Fayt, y por último, López y Vázquez.

El voto del Dr. Nazareno destacó que la primera cuestión a analizar una vez considerada procedente la vía del amparo, era la forma en que las normas de emergencia habían sido dictadas. Encontró así la aguja en el pajar que le permitió desentrañar el complejo y perverso andamiaje jurídico dictado para paliar la emergencia.

Las normas deben ser válidas en cuanto a su forma y en cuanto a su sustancia.

Primero hay que analizar el aspecto formal que obliga a confrontar si el procedimiento utilizado se ajustó a lo dispuesto por la Constitución, y en segundo lugar, superado este tamiz, corresponde analizar si el fondo a su vez se ajusta o no a la Carta Magna.

¿Por qué es tan importante el aspecto formal? Porque si la norma ha sido dictada violando el procedimiento previsto, carece de relevancia el análisis de la cuestión de fondo pues ya se ha consumado la violación a la Constitución.

Siguiendo esta lógica, la primera pregunta de la Corte consiste en averiguar a qué tipo de norma se está enfrentando. La complejidad de la pregunta obedece a la gran profusión y proliferación de normas de distinta naturaleza dictadas en el marco de la crisis económica y política.

Para poner orden y armar la arquitectura jurídica, la Corte encuentra el principio del ovillo en la ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario.

160

pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria; delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la misma hasta el 10 de octubre de 2003, con arreglo a las bases que conforman el límite y sendero de la política legislativa.

La Corte parte de esta ley porque la Constitución pone en cabeza del Poder Legislativo la declaración de la emergencia, que fue la circunstancia desencadenante de la legislación cuestionada por la Provincia de San Luis. Es el Congreso el único órgano facultado para declarar la emergencia y en consecuencia, es él también el que debe determinar el lapso temporal de duración del estado de emergencia, con principio y fin.

A su vez, de las diversas disposiciones de la ley 25.561, se desprende que las bases de la delegación, con arreglo a lo dispuesto en el art. 76 de la CN, quedó circunscripta a "...establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias" (art. 2º), a reestructurar "las deudas con el sector financiero" (art. 6º, segundo párrafo), "establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras" (art. 6º, tercer párrafo) y disponer "las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas" (art. 6º, párrafo 5).

Con estas directivas, el Ejecutivo dictó el 4 de febrero de 2002 el decreto 214, que en su artículo segundo dispuso la conversión de todos los depósitos en dólares estadounidenses existentes en el sistema financiero a pesos, a razón de pesos uno con cuarenta centavos por cada dólar estadounidenses. En el art. 4º del mismo decreto, determinó que a los depósitos reprogramados se les aplicaría un coeficiente de indexación llamado C.E.R.

Este nuevo régimen modificó la política monetaria de convertibilidad seguida por el Estado durante una década, alterando el valor de las prestaciones y bienes reinantes en la época de la paridad \$ 1= u\$s 1.

Por ello, la Corte aclara que en el caso no se cuestiona el cambio de políticas o de sistema legal vigente, pues es facultad de los gobiernos enfrentar los cambios que se avecinan, sino que se busca determinar si estos cambios fueron ejercidos dentro de los márgenes constitucionales para la validez de tales decisiones.

La Corte va a limitarse al estudio del art. 2º del decreto 214, dejando en claro que existe una notoria asimetría entre las distintas situaciones jurídicas creadas por este decreto, a pesar de lo cual deja circunscripta la solución del caso a la situación de la Pcia. de San Luis.

Y deja en claro que impone esta solución "pues de lo contrario, se correría el riesgo de provocar respuestas inicuas, que solo contribuirían a ahondar aun más la desorientación provocada tanto por la *deficiente técnica legislativa que se vislumbra en las disposiciones bajo examen*, las cuales han genera-

nación de pautas claras, han provocado un incierto y prolongado estado de *incertidumbre*, que aún no ha sido disipado...".

¿Cuál es la naturaleza del decreto 214? ¿En qué marco normativo se asienta?

La esquizofrenia está planteada. En los considerandos del decreto 214 el Ejecutivo justifica su dictado en la situación de emergencia declarada por la ley 25.561. Recordemos que esta ley le delegó facultades al Ejecutivo para resolver la problemática relacionada con el capital de los ahorristas. Sin embargo, en el último párrafo de su texto se establece expresamente que su dictado enmarca en uso de las facultades conferidas por el art. 99, inc. 3 de la CN.

¿Cuál es la fuente correcta?

La simultánea apelación a distintos e incompatibles orígenes puede obedecer a dos supuestos ambos perniciosos: la ignorancia o la malicia. Ninguna de las dos se presume según la doctrina del más alto Tribunal.

La Corte responde a la pregunta sin escapar al dilema. El Poder Ejecutivo no tenía facultades para legislar en el marco del art. 99, inc. 3, simplemente porque no invocó una situación de emergencia distinta a la ya declarada por el Congreso que ameritara el uso de las facultades excepcionales que exige el dictado de decretos de necesidad y urgencia.

Por otra parte, no justificó el legislativo los supuestos de "necesidad" y "urgencia" que hiciera imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Y su prueba hubiera resultado nula a la luz de la toda la legislación dictada por el Congreso en el marco de la emergencia, empezando por la ley 25.561 y luego leyes 25.563, 25.587, 25.589 en pleno ejercicio de sus facultades.

Si el Poder Ejecutivo Nacional recibió facultades delegadas por la ley 25.561, el instituto de la delegación legislativa era su único marco de actuación.

El Congreso fijó una pauta muy clara desobedecida por el PEN. El Congreso sólo lo habilitó para afrontar la crisis. ¿Cuál era el límite y el objetivo de la política legislativa prefijada por el Congreso? Preservar el capital de los ahorristas, incluidos los depósitos en moneda extranjera.

La ley 25.561 no le dio un cheque en blanco ni facultades para alterar el valor del capital depositado.

Por ello, tratándose de un decreto delegado, se excedió de las facultades delegadas por el Congreso, al transformar la sustancia de los depósitos bancarios.

8. RECAPITULACIÓN

La reforma incorporó la posibilidad de la delegación legislativa junto con otras facultades para legislar. Si bien en el texto aparecen como excepciones,

101

...en la práctica, en regas, que impuso transformas al ejecutivo en colegislador en desmedro de la división de poderes.

Antes de la reforma, se pensaba que la constitucionalización de prácticas viciosas, lograría la transparencia anhelada al sacarlas de la clandestinidad.

A más de 10 años de la reforma, los mecanismos de control del Congreso, previstos por la Constitución no han logrado ser efectivos. En efecto, tanto los reglamentos delegados, los decretos de necesidad y urgencia y la promulgación parcial de normas, quedan sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente de todas estas facultades legislativas que ostenta el Poder Ejecutivo.

No debemos olvidar que el daño que producen las normas inconstitucionales no solo lesiona derechos particulares sino que es un puñal que se clava al Estado de Derecho como forma de gobierno.

Estar fuera de la Constitución no es otra cosa que estar fuera del derecho. Estar fuera del derecho es estar fuera del Estado. Y estar fuera del Estado, es volver a la barbarie.

CAPITULO III.1

EL PODER JUDICIAL FEDERAL DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Tradición Norteamericana y condimento Europeo. — 3. Una Corte Suprema. — 4. Lo federal y lo local. — 5. Esquema organizativo del Poder Judicial. a) Tribunales Federales con asiento en la Capital Federal. b) Tribunales Federales con asiento en el interior del país. — 6. Organización del Poder Judicial de las Provincias. — 7. Organización del Ministerio Público Nacional. — 8. Ejercicio de la abogacía. — 9. Lo internacional en el campo de los derechos humanos. — 10. Del derecho de defensa a la tutela judicial efectiva. — 11. Poder Judicial y participación ciudadana. — 12. Los procedimientos.

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Nacional, en su Sección Tercera del Libro Segundo, concibió a la judicatura federal como un *verdadero poder del Estado*.

Esta estructuración se deriva de la matriz de la Constitución de Filadelfia de 1787, que actuó como modelo en la materia, y que básicamente predica la organización de la justicia federal de modo independiente e imparcial, intentándola colocar lejos de la influencia del poder político. En tal sentido, la permanencia en el cargo de los jueces mientras dure su buena conducta (art. 110) y demás garantías funcionales e institucionales, que hacen a la postre a lo que podría denominarse "estatuto del juez", dan cuenta de esta cosmovisión imperante en la mente del constituyente originario, prevenido de la suma del poder público del período anterior (art. 29).

2. TRADICIÓN NORTEAMERICANA Y CONDIMENTACIÓN EUROPEA

Curiosamente, la atribución más importante de la justicia federal, que es el control difuso de constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos, no es mencionada por la propia norma de base, derivándose de una interpretación armónica y sistemática de los arts. 31 y 116 constitucionales.

Desde un punto de vista de la jurisdicción federal ordinaria, la atribución consustancial del Poder Judicial es la de "impartir justicia" o "decir el derecho" (*iuris dictio*), lo cual también aparece como facultad implícita en todo obrar jurisdiccional. De todos modos, a una impronta si se quiere anglo norteamericana de la figura del juez, se vinieron a agregar una pesada tradición hispano-indiana de fuerte tono escriturista en los procedimientos, y una gran presencia de la legalidad objetiva fruto del sistema europeo continental-romanista.

A este esquema mínimo (o minimalista, si se quiere) se vinieron a sumar encima instituciones de cuño netamente europeo de posguerra, a partir de la reforma de 1994. Centralmente, nos estamos refiriendo al Consejo de la Magistratura (art. 114, CN) y al Jurado de Enjuiciamiento (art. 115, ídem), amén del Ministerio Público en otra sección aparte (art. 120).

Nótese que las fricciones han pasado fundamentalmente por el hecho de que el Consejo no sólo recluta a los cuadros judiciales, sino que en la letra de la reforma constitucional, cuenta con importantes funciones reglamentarias, administrativas y presupuestarias, que lo hacen competir con la Corte Suprema por ser la cabeza en definitiva del Poder Judicial.

3. UNA CORTE SUPREMA

Dentro de esa inteligencia, la Constitución crea un solo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando la creación de los órganos judiciales inferiores en manos del Congreso (conf. art. 108). Periódicamente el Congreso dicta leyes que van estableciendo nuevos juzgados y Cámaras de apelaciones en distintos puntos del país, organizándose de ese modo el "mapa judicial federal".

A diferencia de lo que aconteció con el texto originario de 1853, a posteriori la Constitución no fijó la cantidad de miembros de la Corte, la que ha fluctuado en el tiempo de cinco a nueve miembros (1990), y que en la actualidad se halla fijada por la ley 26.183.

El diagrama constitucional en lo que concierne a la propia Corte es bastante esquemático (arts. 111 a 113), y oscurece una realidad que es que la Corte a lo largo de nuestra historia institucional no sólo se ha comportado como un tribunal más, sino también como cabeza de un Poder del Estado. Piénsese, al respecto, las Acordadas convalidatorias de los gobiernos de facto de 1930 y de 1943, y en la construcción de la doctrina de la emergencia a lo largo de todo el siglo XX.

En definitiva, la Corte Suprema no configura ni conforma una "tercera instancia" de revisión. Según el art. 117 constitucional, tiene competencia originaria (asuntos internacionales y cuando una Provincia es parte), y por vía de apelación, ella última estructurada fundamentalmente en rededor del recurso extraordinario federal del arts. 14 y sigtes. de la ley 48.

4. LO FEDERAL Y LO LOCAL

Una difícil delimitación constitucional pasa por segregar lo que hace a la estricta competencia federal, en contraste con la jurisdicción local mentada por el art. 5º constitucional.

La lógica del art. 116 constitucional, norma central en la referida distribución de competencias, se conecta estrechamente con aquella estampada en el art. 75 inc. 12, relativa a la reserva de las jurisdicciones provinciales o locales en cuestiones apodadas de *derecho común*.

Si se sigue el esquema de esta última norma, se comprobará que la sanción de los llamados Códigos de fondo (Civil, Penal, de Comercio, de Minería, y el aún no dictado de Trabajo y Seguridad Social, agregado en 1957) corresponden al Congreso, pero el juzgamiento de sus causas es provincial.

La materia federal se revela así compleja y residual. Lo que "no es" derecho común, pertenece en principio al ámbito interprovincial e internacional (art. 116).

Recuérdese que las primigenias leyes de organización judicial argentina como la ley 27 y la ley 48 tuvieron, como sus homólogas norteamericanas, la finalidad de asegurar por ante todo la *unión nacional* a través del obrar de la justicia federal y en particular de la Corte Suprema de Justicia.

Por lo demás, los adelantos tecnológicos (p. ej. transporte y telecomunicaciones) y las crecientes asunciones de cometidos por parte del Estado Nacional a lo largo de gran parte de la segunda mitad del siglo XX contribuyeron a "desfederalizar" nuestro sistema político, imputando muchas tareas al poder central y no al poder local. Algunas privatizaciones a lo largo de la última década de la pasada centuria paradójicamente tuvieron análogo efecto (jubilaciones, riesgos de trabajo), todo ello acrecentando la "materia federal".

5. ESQUEMA ORGANIZATIVO DEL PODER JUDICIAL NACIONAL

Con el gobierno patrio, las funciones del Estado fueron distinguidas en legislativas, ejecutivas y judiciales, aunque la división de poderes no fue exacta. El Poder Judicial tuvo un papel importante en los textos constitucionales en los cuales se impuso la independencia de este poder con respecto a los otros dos.

En 1812, la Real Audiencia fue reemplazada por la Cámara de Apelaciones, siendo los oidores sustituidos por conueces criollos. Sus cargos duraban mientras mantuvieron su buena conducta y sus atribuciones fueron exclusivamente judiciales.

En los comienzos patrios, los jueces tuvieron clara dependencia del Poder Ejecutivo y, en segundo lugar, de la Asamblea Legislativa.

103

El Poder Ejecutivo entendía en los conflictos acaecidos en el ámbito cas-trense, las causas de contrabando y debía vigilar el cumplimiento de las leyes y la recta administración de justicia. Asimismo, los jueces dependían del Poder Legislativo pues no podían interpretar la ley, debiendo aplicar su texto expreso, y elevar toda duda al respecto al mencionado poder.

Las Constituciones de 1819 y 1826 establecieron una Alta Corte de Justicia para funcionar en lugar de la Cámara de Apelaciones (1).

Luego con la sanción de la Constitución Nacional de 1853-60, el Máximo Tribunal del Poder Judicial como ya se expuso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. La misma se instaló el 15 de enero de 1863 y en septiembre del año siguiente comenzó a editar la colección de "Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", que sigue publicándose actualmente.

En este orden de ideas y de experiencias, colacionamos al art. 108 de la Constitución Nacional cuando establece que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación está formada hoy transitoriamente por siete jueces. El tribunal —como cabeza del Poder Judicial de la Nación—, es la instancia jurídica final tanto para los asuntos en los que tiene competencia originaria, como en aquellos que plantean cuestiones de inconstitucionalidad, básicamente por conducto del recurso extraordinario federal.

Otro órgano que compone la cabeza del Poder Judicial es el Consejo de la Magistratura, que es quien selecciona las ternas de los candidatos a magistrados y realiza la acusación de los mismos ante el Jurado de Enjuiciamiento. El Consejo está integrado por trece miembros (ley 26.080): tres jueces del Poder Judicial, seis legisladores, dos representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito científico y académico. Mientras que el jurado de enjuiciamiento, es el órgano encargado del juzgamiento de los jueces de los tribunales inferiores. Formado por nueve miembros, está integrado por: un ministro de la Corte Suprema, dos jueces de cámara, tres legisladores y tres abogados de la matrícula federal.

a) Tribunales Federales con asiento en Capital Federal

Con un rango inferior a los citados existen los Tribunales Nacionales. Son órganos encargados de administrar la justicia federal; entre ellos encontramos las Cámaras de Apelaciones y los juzgados de Primera Instancia. En materia penal tendríamos que agregar a la Cámara Nacional de Casación Penal, que es un paso previo al acceso a la Corte Suprema para el tratamiento de cuestiones constitucionales (2).

(1) <http://www.mapadelestado.org.ar>.

(2) <http://www.pjn.gov.ar>.

-Justicia Nacional de Apelaciones del Trabajo
- Justicia Nacional de Apelaciones en lo Civil
- Justicia Nacional de Apelaciones en lo Comercial
- Justicia Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
- Justicia Nacional de Casación Penal
- Justicia Nacional de la Seguridad Social
- Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal
- Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal
- Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
- Justicia Nacional en lo Penal Económico
- Justicia Nacional Electoral.

b) Tribunales Federales con asiento en el interior del país

A los efectos de tener un mejor acceso a la jurisdicción para todos los justiciables, los tribunales federales además de tener su asiento en la Capital Federal están organizados en cada localidad o provincia del interior del país, que por el número de causas exijan una cámara y/o juzgados para cada una de las materias (3).

- Justicia Federal de Bahía Blanca
- Justicia Federal de Comodoro Rivadavia
- Justicia Federal de Córdoba
- Justicia Federal de Corrientes
- Justicia Federal de General Roca
- Justicia Federal de La Plata
- Justicia Federal de Mar del Plata
- Justicia Federal de Mendoza
- Justicia Federal de Paraná
- Justicia Federal de Posadas
- Justicia Federal de Resistencia
- Justicia Federal de Salta
- Justicia Federal de Santa Fe
- Justicia Federal de San Martín
- Justicia Federal de Tucumán

(3) Ibídem.

En 1810 existían, en virtud de la Real Ordenanza de Intendentes de 1782, ocho intendencias (Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Paraguay, Cochabamba, La Paz, La Plata y Potosí) y cuatro gobiernos militares en el territorio virreinal (Moxos, Chiquitos, Misiones y Montevideo). Estas circunscripciones se fueron separando del Río de la Plata para formar los actuales países de Paraguay, Bolivia, la República Oriental del Uruguay y la República Argentina. El territorio argentino se formó a partir de las intendencias de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, las cuales se fueron desgajando en las provincias que hoy conocemos (4).

A partir de 1820, con excepción de la Constitución unitaria de 1826, la organización de la administración de justicia quedó reservada a cada provincia. Se terminó con la estructura de intendencias, quedando todas las circunscripciones con el mismo rango de provincias autónomas. Todas ellas adoptaron para sus gobiernos la forma republicana y representativa, dividiendo las funciones del estado provincial en legislativa, ejecutiva y judicial.

Al desaparecer las autoridades nacionales en 1820, y asumir las provincias todos los poderes en cada jurisdicción, éstas introdujeron reformas judiciales para asegurar su independencia. Los cabildos fueron abolidos y con ellos la justicia capitular, tornándose necesario establecer juzgados para las causas civiles y criminales que no correspondieran a un fuero especial. Los jueces de primera instancia ocuparon el lugar de los alcaldes, mientras que para asuntos menores se establecieron jueces de paz en las parroquias. Las cuestiones comerciales eran entendidas en algunas provincias por juzgados comerciales creados al efecto, y en otras por jueces ordinarios. Los conflictos en materia de hacienda eran competencia del gobernador, pero las apelaciones se efectuaban ante las cámaras de justicia. Asimismo, en cada provincia se estableció un tribunal superior de apelaciones y para los recursos de segunda suplicación, nulidad e injusticia notoria, el gobernador creaba un tribunal especial para la causa que se disolvía una vez terminada la misma.

Se suprimió el fuero personal, salvo para las causas exclusivas sobre delitos de naturaleza militar o eclesiástica, que sólo eran juzgados por los jueces de las respectivas jurisdicciones.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo continuó interviniendo en las causas judiciales debido prioritariamente a que no todas las provincias podían mantener los jueces y tribunales que había que establecerse, sumada a la escasa actividad judicial en algunas de ellas, a la insuficiencia de abogados, y a que en muchas provincias el Poder Ejecutivo tenía, por ley, competencia en las apelaciones judiciales.

Luego con la Constitución Nacional de 1853-60 al crear un Estado Federal —arts. 1º y 5º de la CN—, cuando se trata de cuestiones que no sean federales

(4) <http://www.mapadeleestado.org.ar/item.aspx>.

cada provincia argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las funciones jurisdiccionales atento lo reglado por art. 129 de la CN— tienen para resolver sus situaciones locales una justicia ordinaria propia, formado por un Poder Judicial similar al nacional, con un Tribunal Superior, Cámaras de Apelaciones, Juzgados de Primera Instancia y Ministerio Público.

7. ORGANIZACIÓN ESQUEMÁTICA DEL MINISTERIO PÚBLICO NACIONAL

A partir del art. 120 de la CN, los Fiscales y Defensores ya no son más miembros del Poder Judicial Nacional; ahora el Ministerio Público es un órgano independiente compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Su jefatura es ejercida por el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, respectivamente.

El Ministerio Público Fiscal está integrado por el Magistrado máximo que es el Procurador General de la Nación, los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fiscales ante la Cámara y Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional, Fiscales ante las Cámaras y Juzgados de Primera Instancia Nacional y Federal en lo Civil y Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, Seguridad Social y Electoral.

El Ministerio Público de la Defensa está integrado por la Defensora General de la Nación, el Defensor ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Defensores de menores e incapaces, Defensores ante la Cámara de Casación Penal y Segunda Instancia, Defensores Públicos Oficiales, Tutores y Curadores Públicos.

8. EJERCICIO DE LA ABOGACÍA

Existe para el abogado que se gradúa dos tipos de desarrollo profesional:

1. **La carrera judicial:** Desde el ingreso como meritorio se extiende hasta el rango de secretario. Los ascensos son reglamentados por las diferentes Cámaras y son los jueces quienes eligen a los nominados. La carrera judicial está regida en última instancia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
2. **La abogacía "strictu sensu":** En la Argentina existen más de 30 entidades de enseñanza de las ciencias del derecho (de las cuales 14 son públicas). Actualmente, hay más de 125.000 abogados recibidos (y 150.000 estudiantes inscriptos). La carrera insurge 5 años de estudios en promedio.

9. LO INTERNACIONAL EN EL CAMPO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Repárese que en materia de derechos humanos, la Corte Suprema no es la última instancia, quedando eventualmente expeditas las instancias supra-

165

nacionales de protección internacional de los derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington D.C., y la Corte Interamericana con asiento en la ciudad de San José de Costa Rica.

Todo ello ha traído un problema mayúsculo de interpretación aplicativa del denominado "bloque federal de constitucionalidad", del control de constitucionalidad y de "convencionalidad", y la cotización de los criterios oriundos de esas instituciones, en sede interna o doméstica.

10. DEL DERECHO DE DEFENSA A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Como fruto de la tradición anglonorteamericana, la Constitución original puso el acento en "la defensa en juicio de la persona y de los derechos", a la que no vaciló en calificar de "inviolable", de acuerdo a la célebre fórmula contenida en el art. 18 constitucional.

Así, la jurisprudencia de nuestra Corte fue perfilando esta figura de la defensa en juicio, no sólo en materia penal sino latamente en lo que se considera "causa civil".

Empero, a nivel mundial en las últimas décadas se ha registrado un fuerte movimiento hacia lo que se ha denominado "tutela judicial efectiva".

Lamentablemente, muchas veces ha acontecido tanto en Argentina como en otras latitudes que no basta la existencia de tribunales de justicia, ni la sanción de normas procedimentales. Es menester acercar la administración de justicia al justiciable, crear mecanismos idóneos y efectivos para que la impartición de justicia sea real y no meramente quimérica.

11. PODER JUDICIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Estrechamente vinculado con lo anterior, en la actualidad se buscan instrumentos que hagan que el justiciable se sienta "parte" no sólo desde el ángulo procesal, sino en el sistema judicial en su conjunto.

La concentración procesal, la oralidad, las audiencias públicas, la institución de los "amigos del Tribunal", todo ello intenta acortar la brecha que suele existir entre los que reclaman justicia y los que la imparten.

12. LOS PROCEDIMIENTOS

En una célebre trilogía, Germán Bidart Campos afirmaba que el derecho a la jurisdicción se satisfacía no sólo con la posibilidad de que el justiciable pudiese acudir a un tribunal en procura de justicia, sino era necesario asegu-

rar el derecho de defensa de las partes y el derecho a una decisión oportuna y fundada en derecho. Además, ello irrogaba al Estado la obligación de crear precisamente esos tribunales, dotarlos de jurisdicción, de competencia y de procedimientos idóneos (5).

Aquí es donde se viene a engarzar lo procesal con lo sustancial.

Lo procesal será como vimos materia local o provincial, sin perjuicio de lo cual las garantías hoy vienen reclamadas desde el derecho internacional de los derechos humanos que goza de jerarquía constitucional, como acontece con las insertas en el art. 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos.

(5) V. CARNOTA, WALTER F., *Instituciones de Derecho Público*, Buenos Aires, 2005, p. 139.

CAPITULO III.2

EL ROL DEL JUEZ. POTESTADES Y LIMITACIONES

SUMARIO: 1. Planteo del tema. — 2. El rol del Juez. — 3. Nuevas realidades. Funciones y Constitución. — 4. Valoración de las tareas de los jueces. — 5. Sus potestades y sus limitaciones. a) Potestades del juez. b) Limitaciones del juez. — 6. Responsabilidad de la decisión. — 7. Limitaciones al control de constitucionalidad a través de los fallos de la CSJN. a) Análisis de la Constitución Nacional. b) Criterios Generales de la CSJN. — 8. Límites específicos del control. a) Clara individualización al caso concreto. b) Contradicción manifiesta e inconciliable con la Constitución Nacional. c) Irrazonabilidad evidente. d) Sólidos fundamentos y desarrollo argumentales. e) Estricta necesidad. — 9. A modo de conclusión.

1. PLANTEO DEL TEMA

Cabe destacar que al tratar de responder a la doctrina que considera a las sentencias judiciales como arbitrarias y antimayoritarias surgieron otros planteos, los cuales, es necesario que sean analizados seriamente.

Al respecto, en primer término resulta conveniente examinar el papel del juez, considerando los cambios y las nuevas realidades existentes en los Estados de Derecho.

En segundo término, se debe indagar el rol del juez, su relación con la Constitución y las limitaciones impuestas al ejercicio de las funciones que deben desempeñar los magistrados.

En tercer término, se debe analizar el desempeño de las tareas de los jueces y realizar un juicio de valor al respecto para determinar en qué medida sus sentencias pueden considerarse arbitrarias o antimayoritarias o no.

Todo ello a fin de concluir y responder al interrogante mencionado.

Asimismo, se debe aclarar que en el presente serán expuestos conceptos básicos y fundamentales, tanto generales como propios de nuestro sistema judicial, conforme nuestra Carta Magna y la labor de nuestro Poder Judicial.

107

Si se parte de la base que son evidentes los cambios en el rol de los jueces en nuestro sistema, es posible considerar fases o etapas de ello (1).

Es así que en los años sesenta en nuestro sistema el juez ante un pleito se desempeñaba como intérprete y aplicador de la ley, se refugiaba en su despacho y sin diálogos frecuentes con los hacedores del proceso, aguardaba la recepción del expediente ya finalizado para dictar la sentencia correspondiente.

En un tiempo intermedio, ante la realidad de emergencia económica suscitada en el Estado Benéfactor y el inmovilismo del legislador, los magistrados debieron salvar el derecho de propiedad y el principio de la seguridad jurídica. Por ello su actuar fue más activo, conforme dicha situación.

Finalmente y en años más cercanos, atento a la filosofía económica imperante: el reinado del mercado, la estabilidad económica y el desarrollo del sistema capitalista, es evidente que el papel que deben asumir los magistrados resulta totalmente distinto y más activo que en la etapa anterior mencionada.

Conforme ello, es claro el aumento de los poderes-deberes del juez debido a los fenómenos que constantemente irrumpen en la realidad y que hacen necesaria la asunción de una función directiva y creativa, por parte de los magistrados (2).

Como corolario de esto aparece un juez-legislador y un juez-administrador, no obstante la división de poderes y el régimen democrático de gobierno.

Así, aparecen nuevos sujetos de derecho, tales como la sociedad, el ambiente, las ligas o entidades que los defienden, la pareja, el niño; todos ellos legitimados para contar con una tutela judicial efectiva. Por otro lado, la asunción de funciones jurisdiccionales (por delegación) ha cambiado el papel de los magistrados en el ámbito de la justicia.

Es por lo expuesto que no se puede negar que los años finales de esta década instalan al juez como al gran operador en la renovación del oficio de juzgar y como factor de un nuevo equilibrio para el acceso a la justicia.

3. NUEVAS REALIDADES. FUNCIONES Y CONSTITUCIÓN NACIONAL

Descrita brevemente la realidad actual y las nuevas funciones asumidas por los magistrados, corresponde considerar su vinculación con la Constitución Nacional.

(1) En este sentido: MORELLO, AUGUSTO, "Perfil del Juez al final de la centuria", LA LEY, 1998-C, Sec. Doctrina.

(2) En relación a ello, cabe destacar la importancia del papel de la Corte en nuestro sistema en las más variadas materias como antes no había tenido.

Ello, toda vez que nos encontramos en un gobierno republicano y democrático.

Al respecto, es sabido que toda decisión judicial es constitucional siempre que respete lo delimitado por la Constitución Nacional.

Sin embargo, se comparte la opinión de algunos autores (3) que ante las nuevas realidades que se le plantean a los magistrados, las exigencias normativas derivadas de los derechos constitucionales ya no se ven como límites negativos y deberes de respeto, sino más bien como exigencias de desarrollo y concreción de los mismos: como la fuente central para determinar que se debe ordenar, prohibir y sancionar.

Además, se considera que es necesario construir una noción amplia de juez (4), en el sentido que hay que reconocer la temporalidad, la especialidad, la referencia personal y la proyección material de la tarea judicial (5).

Finalmente, se entiende que la variación del papel del juez se debe apreciar en las tareas que realiza a fin de lograr el correcto funcionamiento de las normas y de la aplicación del derecho.

4. VALORACIÓN DE LAS TAREAS DE LOS JUECES

Ahora bien, no se puede negar que el papel del juez, en la época actual, puede tensionar las razones democráticas del Estado de Derecho conforme lo estatuido en nuestra Ley Fundamental y por ende, que irroguen problemas de legitimidad del poder judicial.

Ello, toda vez que el traspaso del poder decisorio a manos de los jueces puede afectar ciertos derechos y garantías de los ciudadanos.

Sin embargo, se entiende que ello no significa que las sentencias judiciales sean "per se" antimayoritarias y antidemocráticas.

Al respecto, se concibe que si los jueces asumen su nuevo rol atendiendo a los derechos fundamentales, a los principios constitucionales y conforme el contexto social, no se vulneraría la división de poderes.

Es en este punto donde se puede considerar lo sostenido por Dworkin (6). Hay un aspecto por el cual una Constitución podría parecer no democrática y

(3) En este sentido: CHAUMET, MARIO EUGENIO, "Las escuelas judiciales para el Estado Constitucional". Texto publicado en www.centrodefilosofia.org.ar; en Revista de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Universidad de Rosario.

(4) V. CARNOTA, WALTER F., "El juez en la reforma constitucional de 1994", en BIDART CAMPOS, GERMÁN J., y otro (Coordinadores), *A una década de la reforma constitucional*, Buenos Aires, 2004, p.111.

(5) Al respecto se puede ver: CIURO CALDANI, MIGUEL ANGEL, "Una nota histórica sobre la tarea judicial". Texto publicado para clase en la Maestría en Magistratura del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA.

(6) DWORKIN, RONALD, *Liberalismo, Constitución y Democracia*, Buenos Aires, 2003.

168

es que los jueces de los tribunales no son electos sino nombrados y se desempeñan de por vida, salvo mala conducta extraordinaria. Es por ello, que un sistema político que confiere tanto poder a los jueces parece ofender los principios fundamentales de una democracia.

No obstante, en nuestro sistema existen otros funcionarios con gran poder y que no son elegidos, tales como los ministros, jefes de gabinete de ministros; quienes pueden causar más daño en una semana que cualquier juez en toda su carrera y no deben rendir prácticamente cuenta de su gestión.

¿Lo antedicho autorizaría, entonces, a sostener que nuestro sistema no es democrático? Se considera que el nuevo papel asumido por los jueces no compromete los principios democráticos.

5. SUS POTESTADES Y SUS LIMITACIONES

a) Las potestades del juez

La celeridad del proceso civil y la profundidad del rol del juez como "director del proceso" parecieran ser los principales objetivos que pretenden alcanzar las modificaciones introducidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que concluyeron en la ley (7).

En su dictamen el senador Ricardo Branda indicó que la reforma "...pro-vee al proceso judicial normas que tiendan a facilitar, simplificar y agilizar ciertos aspectos del procedimiento, con miras a lograr, asimismo una razonable unidad en el espíritu del ordenamiento vigente..." (8).

Recordemos que el juez, si bien tenía un papel activo en las diferentes etapas del proceso, estas medidas resultaban de aplicación potestativa en muchos casos, pero ello se ha reformado transformándose en un verdadero imperativo legal, cuyos deberes disciplinarios, ordenatorios e instructorios son obligatorios para los magistrados de la causa, luego de la modificación de los arts. 34, 35 y 36 del CPCCN, cuyo incumplimiento podría traerles cierto grado de responsabilidad, en su inacción judicial. Dicha obligación resulta desmesurada si tenemos en cuenta las múltiples tareas que ostenta un magistrado, que va desde la administrativa interna de su propio juzgado hasta su asistencia a las audiencias (conciliatorias, confesionales, preliminares...), cuestiones incidentales, interlocutorios y el dictado de la sentencia definitiva.

Más concretamente hacemos referencia a la modificación de la palabra "podrán"—facultativo—por "deberán"—imperativo—en los artículos mencionados.

(7) OSTROWER, RICARDO y SORIA, SANTIAGO, "Reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", LA LEY, del 12/12/2001.

(8) Dictamen en el proyecto de ley del Senador Branda, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Sesiones Ordinarias de 1999, Orden del día N° 253, Dirección Publicaciones, impreso el día 14 de mayo de 1999.

El deber es un mandato legal que nos fuerza a actuar de determinado modo frente a situaciones especificadas. Se muestra como un vínculo genérico-social, donde debe responderse al grupo social en cumplimiento de sus intereses por cargos por el mismo otorgados (9). En cambio por facultades debe entenderse a las "atribuciones que la ley confiere expresa o implícitamente pero cuyo ejercicio depende del arbitrio de ellos, quienes por tanto pueden asumir o no la conducta correspondiente (10).

Esto marca una variación significativa, en la gran división que existía entre el sistema *dispositivo* e *inquisitivo*. En el tipo procesal civil predomina el sistema *dispositivo*, donde se sigue exclusivamente el señorío de la voluntad de las partes, quienes no solamente fijan y determinan el objeto litigioso y aportan el material de conocimiento, sino que también tienen el poder de impedir que el juez exceda los límites fijados a la controversia por la voluntad de las mismas; éste es el imperante en el derecho de procedimiento civil.

Por otro lado, el proceso *inquisitivo*, traslada el dominio de la actividad procesal al magistrado que no solamente dirige e impulsa el proceso, sino también promueve su iniciación y realiza los actos de investigación tendientes a la asunción del material de conocimiento. Así enunciado, el tipo procesal *inquisitivo* solamente se da en la etapa instructora del proceso, cuya naturaleza jurisdiccional es discutible (11).

El actual proceso civil, tiene características "*dispositivas mixtas*", ya que toma rasgos típicos de ambos sistemas; por el lado *inquisitivo* puro en cuanto existen deberes marcados en los artículos citados, y en lo que respecta al *dispositivo* tenemos funciones que sólo pueden ejercer las partes como ser: regulación de honorarios, apelación, etc.

Pero nos queda el interrogante de si esta modificación ha sido o no beneficiosa para la celeridad e inmediación judicial de los miles de juicios que hoy tramitan en los distintos fueros civiles, comerciales, contenciosos administrativos, etc. La respuesta no podría ser otra que si, ya que, el juez no debe ser un mero espectador en las causas que por él tramitan, sino por el contrario, deberá tomar intervención saneando nulidades (art. 34 inc. 5 apart. B), evitando la paralización del proceso (art. 36 inc. 1), intentando una conciliación total o parcial del conflicto (inc. 2), proponiendo a las partes formulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria (inc. 3), ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos (inc. 4).

Si cambiamos el interrogante y decimos, si estas modificaciones son practicable, la respuesta no sería tan fácil. Por un lado, tenemos totalmente satu-

(9) BOURGUIGNON, MARCELO, "Deber de saneamiento del juez", Revista Jurídica Universidad Nacional de Tucumán, junio de 1988.

(10) CCiv., Com., Lab. y de Minería, Esquel, Chubut, sala Civil in re: "A.F. s/ Suc. ab intestato" interlocutorio del 7/12/2000, SAJ Q 0011473.

(11) MARANIELLO, PATRICIO A., Manual de despachos e interlocutorios judiciales, Buenos Aires, 2001.

169

personal resulta sumamente escaso, ello nos trae como resultado la poca probabilidad de llevar adelante con eficacia estos beneficios innovativos, sin una mejora correlativa en los servicios de justicia imperantes.

b) Limitaciones del juez en la voluntad del pueblo

Otra cuestión interesante de remarcar es el preámbulo de la Constitución Norteamericana que fija como sede de poder al pueblo (*we the people*) mientras que su equivalente de Perú en su art. 45 establece "que el poder del Estado emana del pueblo".

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 21 inc. 3º asevera que "... La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto...".

6. RESPONSABILIDAD EN LA DECISIÓN

Alfonso Santiago (h.) expresa que pareciera que se da aquí un supuesto que guarda analogía con las conclusiones derivadas del denominado "experimento de Milgram": los jueces, como las demás personas, pueden ser capaces de adoptar cualquier clase de decisión en la medida en que piensen que pueden transferir a otros la responsabilidad final de las mismas (12).

7. LIMITACIONES AL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD A TRAVÉS DE LOS FALLOS DE LA CSJN (13)

La declaración de inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional, ya que deja de aplicar al caso concreto una normativa elaborada por los otros dos poderes del Estado —Poder Legislativo y Poder Ejecutivo—.

Lo complejo de esta situación se ciñe al hecho que se está analizando el juego armónico de funciones específicas de cada uno de los poderes del Estado. Si tenemos en cuenta que la función específica del Congreso es la de dictar la ley —art. 75 de la CN— y el Ejecutivo la promulga, la publica y la

(12) ALFONSO SANTIAGO (h.), "La dimensión temporal del derecho y el consciente y deliberado apartamiento de los principios de legalidad e irretroactividad en materia penal por parte de la Corte Suprema en el caso 'Simón'", ED, 14 y 15/11/2005.

(13) MARANELLO, PATRICIO, "Límites al control de constitucionalidad a través de la visión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", EIDial, Año IX - N° 2016, 17/4/2006.

ejecuta —art. 99 inc. 2 y de la CN—, al Poder Judicial tiene la tarea de interpretarla y controlar que la misma no altere los designios de la Constitucional Nacional —arts. 28 y 116 de la CN—.

Es por ello que si bien el control de constitucionalidad es una de las funciones más importantes que ostenta la judicatura, dicha tarea se encuentra limitada a ciertos parámetros, que fueron establecidos por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación: algunos de ellos se desarrollarán en este capítulo.

a) Análisis de la Constitución Nacional

Si bien la Constitución Nacional no expresa explícitamente el instituto del control de constitucionalidad, amplia doctrina y jurisprudencia la considera inmersa en el art. 116 de la Constitución que expresamente dice: "*corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75; y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un estado o ciudadano extranjero...*".

Las tres palabras claves de este artículo son "*conocimiento*", "*decisión*" y "*causas*". Todas ellas indican la función específica y básica que le corresponden tanto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como a los tribunales inferiores de la Nación —lo que se conoce con el nombre de control difuso— en referencia al control de constitucionalidad.

Con la palabra "*conocimiento*" nos está indicando que tendrá que conocer en forma exclusiva sobre puntos regidos por la Constitución, sin poder asumir otro órgano del Estado la iniciación del planteo, es decir, no existe una etapa previa administrativa o extrajudicial del control de constitucionalidad sino será primera, segunda y tercera instancia del poder judicial.

En la "*decisión*" nos hace referencia a que no sólo tomará conocimiento del conflicto sino tendrá que decidir, sin ningún tipo de excusa, como por ejemplo: ambigüedad interpretativa, lagunas normativas, entre muchas otras (en sentido concordante, art. 15 del Cód. Civil). Pero la decisión estará dirigida al caso concreto y a las partes involucradas en la causa, aunque la cuestión tenga incidencia colectiva, porque sea o no de un interés colectivo la cuestión, siempre estará signando a las personas que están dentro del contexto físico, moral y psicológico del expediente.

Aquí tampoco se puede negar su decisión por tratarse de cuestiones políticas no judiciales, ya que todo es justiciable, pero ello no significa que luego el planteo pueda ser rechazado por aspectos formales o materiales.

...mento y otro relativo a las causas, la interpretación que debe hacerse es que los constituyentes lo quisieron referir a toda cuestión contenciosa, entre dos partes —actora y demandada—, además del rasgo de la generalidad, es decir, al no haber distinciones entre qué tipos de causas están, serán regidas tanto para las causas principales, accesorias, sumarisimas, etc. No en vano la jurisprudencia de la propia Corte ha tejido una vasta jurisprudencia en torno a este concepto, para delimitar su competencia tanto originada ("causa civil"), cuanto apelada (conf. art. 2º de la ley 27).

b) Criterios generales de la Corte Suprema de Justicia

Como ya se dijo, la invalidez de una norma al caso concreto solo será practicable cuando por la gravedad de tales exámenes pueda estimárselos como la *ultima ratio* del orden jurídico (14).

Si el juez no lo considera de *ultima ratio* del orden jurídico la causa no podrá pasar a la etapa de control, ya que la situación previa no fue sorteada. Aquí tiene una importante inferencia la función del juez, donde debe obviar lo peticionado por las partes para este análisis, ya que es una cuestión que se suscita por su doble rol: guardián directo de la Constitución e integrante de un poder del Estado.

Al respecto podemos agregar (15) que existe una presunción de validez constitucional de las leyes y normas administrativas, por lo que la declaración de inconstitucionalidad es la "*ultima ratio*" del ordenamiento jurídico, como consecuencia de lo que se ha denominado en la jurisprudencia norteamericana "*regla de la evitación*". Estas reglas fueron expuestas por el juez de la Corte Suprema norteamericano Louis Brandeis en el fallo "Ashwander v. Tennessee Valley Authority" del año 1936.

Ello nos lleva a decir, que se deberán agotar todos los medios posibles antes de efectuar dicha declaración, para justamente evitar una decisión en contra de elementos del sistema jurídico (16).

8. LÍMITES ESPECÍFICOS DEL CONTROL

Una vez que el juez haya sorteado la comprensión real de considerar esta cuestión como de *ultima ratio*, y si a pesar de ello considera acertado establecer el control, los límites según la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo podemos segmentar en:

(14) Fallos 303: 531, 790; 304: 849, 892, 1069; 305: 1304; 307: 531, 1656.

(15) CARNOTA, WALTER, *Instituciones de Derecho Público*, Buenos Aires, 2005.

(16) Aún quienes pregonan el activismo judicial, señalan la importancia de evitar el llamado "gobierno de los jueces". V. CARNOTA, WALTER F., "Definiciones sobre el activismo de los jueces", LA LEY Actualidad, 16/8/2007, p.1.

a) Clara individualización al caso concreto

La declaración de inconstitucionalidad, *ultima ratio* del orden jurídico, requiere no sólo el aserto de que la norma impugnada causa agravio sino también la demostración del mismo en el caso concreto (17).

No cabe aquí la ambigüedad en la norma que se quiere dejar sin efecto, pero ello no significa que no se pueda atacar varias normativas o todas aquellas relaciones con la misma; lo que no se puede hacer, es lo que habitualmente ocurre, o sea, citar un conglomerado de normas inconstitucionales como un paquete indivisible, sin ningún tratamiento específico de cada una de ellas.

Del mismo modo, tiene que haber un nexo causal entre la norma y el hecho o el derecho supuestamente vulnerado; sin ello no puede haber una conexión con el planteo en autos, pues se requiere que en el expediente se encuentre violado algún derecho concreto a cuya efectividad aquél obstar.

b) Contradicción manifiesta e inconciliable con la Constitución Nacional

La declaración de inconstitucionalidad es una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (18).

c) Irrazonabilidad evidente

Sabemos que una de las formas de controlar la constitucionalidad de una ley es a través del examen de razonabilidad, pero este "test" sólo será viable si su irrazonabilidad es evidente (19), cuanto que el control que al respecto compete a la Corte Suprema no incluye el examen o acierto del criterio adoptado por el legislador (20).

(17) CSJN *in re*: "Sierra, Edgardo Aníbal c. La Razón S.A.E.E.F.C. y A." del 01/01/1979. Fallos: 301:911 (voto del doctor Elías P. Guastavino). "D' Ambra, Salvador Osvaldo c. Nación Argentina"; Cima S.C.A. c. Nación Argentina"; "Pereyra, Manuela Estela", "Unión Tranviarios Automotor c. Expreso Esteban Echeverría S.R.L. Línea 306"; "Dirección Nacional de Recaudación Previsional c. La Cantábrica S.A.M.I.C.", 1/1/1982; Fallos: 304:849, 892, 1069; Fallos: 307:531, 1656.

(18) CSJN *in re*: "Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) c. Universidad Nacional de Luján s/ aplicación ley 24.521", Fallos: 322:842. Mayoría: Nazareno, Moliné O' Connor, Boggiano, López. Disidencia: Fayt, Belluscio. Abstención: Petracchi, Bossert. 27/05/1999. "Berón, Luisa Victoriana y otros y sus acumulados c. Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos", Fallos: 328:91. Mayoría: Petracchi, Belluscio, Boggiano, Maqueda, Highton de Nolasco. Disidencia: Abstención: Fayt, Zaffaroni, Lorenzetti, Argibay. 15/2/2005. Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema.

(19) CSJN *in re*: "Adamini, Juan Carlos c. Poder Ejecutivo Nacional s/ acción de amparo. Fallos: 323:2409. Ref.: Razonabilidad de la ley. Mayoría: Nazareno, Moliné O' Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano, López. Disidencia: Abstención: Petracchi, Bossert, Vázquez. 14/09/2000.

(20) CSJN *in re*: "Audioacústica S.A. s/ quiebra". Fallos: 324:4404. Mayoría: Nazareno, Moliné O' Connor, Belluscio, Petracchi, López, Bossert, Vázquez. Disidencia: Boggiano. Abstención: Fayt. 19/12/2001. (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).

d) Sólidos fundamentos y desarrollo argumentales

Su procedencia requiere que el planteo pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y contar con no menos sólidos fundamentos, al extremo de proponer un análisis inequívoco y exhaustivo del problema de modo tal que si el recurrente no demuestra cuáles es el alcance de sus derechos y por qué razones cree que lo actuado por el legislador es incorrecto, no deba atenderlo (21).

Es decir, resulta procedente en tanto el interesado demuestre claramente de qué forma las normas impugnadas contrarían la Norma Fundamental, causándole un gravamen, y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (22).

e) Estricta necesidad

Con la nueva composición de la Corte, no debe recurrirse a la inconstitucionalidad, sino cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer lugar. (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema) (23).

Sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución (24). A esto lo podemos denominar: "subsidiaridad constitucional".

9. A MODO DE CONCLUSIÓN

Lo desarrollado en el presente capítulo nos permite concluir que no es posible sostener que las sentencias dictadas por los jueces en nuestro siste-

(21) CSJN *in re*: "Resistencia S.A.I.F. c. L.S. 88 T.V. Canal 11 Formosa s/ daños y perjuicios (provisorio)". Fallos: 325:1201. Ref.: Radiodifusión. Mayoría: Nazareno, Belluscio, Bossert, Petracchi. Disidencia: Moliné O' Connor, Fayt, Boggiano, López, Vázquez. Abstención: 28/05/2002. (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).

(22) CSJN *in re*: "Milone, Juan Antonio c. Asociat S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente - ley 9688". Fallos: 327:4607. Mayoría: Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco. Disidencia: Belluscio, Fayt. Abstención: 26/10/2004. (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Carlos S. Fayt). Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia.

(23) CSJN *in re*: "Ortiz, Francisco y otra c. Banco Central s/ cobro de australes". Fallos: 327:1899. Mayoría: Petracchi, Belluscio, Fayt, Vázquez, Maqueda. Disidencia: Boggiano. Abstención: Zaffaroni. 1/6/2004.

(24) CSJN *in re*: "Petrelli, Claudio Omar c. Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal s/ daños y perjuicios". Fallos: 327:2251. Mayoría: Petracchi, Belluscio, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni. Disidencia: Abstención: Fayt, Vázquez. 24/6/2004. Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema.

ma sean antidemocráticas o antimayoritarias, por sus atribuciones específicas en la división de poderes.

Ello toda vez que tanto por el nuevo papel o por las funciones asumidas por los magistrados resultan coincidentes con la realidad imperante en este siglo.

Se coincide con el criterio que es necesario que los jueces solucionen conflictos de justicia, educación, salud de los ciudadanos, de una manera activa y participativa, sin que ello implique vulnerar los principios democráticos, sino por el contrario mejorarlos.

No obstante, se concibe que tal actividad se realice dentro de los límites de legitimación democrática, logrando razonamientos prácticos y decisiones dialogales para las partes del proceso.

En este aspecto se concluye que más atención y responsabilidad debería tenerse a la hora del nombramiento y selección de los magistrados, a fin de perfeccionar nuestro sistema judicial.

Por otro lado demostramos que el control de constitucionalidad no es algo que los jueces pueden usar en forma cotidiana, sino por el contrario, es una vía excepcional donde el único camino posible para la solución del conflicto es la declaración de inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto o la omisión lesiva.

Para ello el justiciable antes de realizar el *test de razonabilidad* debe expresar que ha tratado de evitarlo por todos los medios a su alcance —regla de evitación de los EE.UU.—, pues no debe quedar implícito de sus relatos, sino por el contrario debe estar expresamente probado fáctica y jurídicamente.

A paso siguiente se debe tener en cuenta las limitaciones que la Corte Suprema de Justicia ha establecido a lo largo de su jurisprudencia, donde las ha agrupado en cinco categorías:

1. Clara individualización al caso concreto.
2. Contradicción manifiesta e inconciliable con la Constitución Nacional.
3. Irrazonabilidad evidente.
4. Sólidos fundamentos y desarrollo argumentales.
5. Estricta necesidad.

Sopesar todo esto en un país donde se ha indagado sobre la inconstitucionalidad de una norma en una medida cautelar —caso "Smith" (Fallos: 325:28)— o en un despacho simple debido al dictado del decreto 1316/02, al amparo de la emergencia económica, muy fuerte deberá ser la concientiza-

172

ción de los ciudadanos de no pedir a la justicia cuestiones que no puede resolver en el modo y la forma que se pretende. Y por el lado de la justicia tendrá que elaborar sentencias que sigan mínimamente los recaudos señalados, en aras de proteger los derechos regulados en nuestra Constitución.



PARTE QUINTA

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA



Todos X
Derecho

CAPITULO I

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LOS TIPOS DE DEMOCRACIA (DIRECTA, SEMIDIRECTA E INDIRECTA) Y LA CONSULTA POPULAR

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Antecedentes históricos. — 3. Antecedentes históricos de Argentina. — 4. Derecho comparado. — 5. Derecho suizo. — 6. Formas directas en los actuales sistemas democráticos. — 7. Formas semidirectas explícitas. — 8. Formas semidirectas implícitas o posibles. — 9. Las consultas populares en la Argentina. — 10. La regulación en la Argentina luego de la reforma de 1994. — 11. Análisis de la jurisprudencia argentina. a) Fallo: "Baeza, Aníbal R. c. Gobierno Nacional s/amparo". b) Fallo de la Cámara Nacional Electoral, en los autos: "Fonrouge, Alberto s/amparo". — 12. Legislación argentina. — 13. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

La consulta popular es una de las dos formas de democracia semidirecta que han sido incorporadas a la Constitución Nacional Argentina por la reforma de 1994; la otra es la iniciativa popular.

La consulta popular, también llamada *plebiscito* o *referéndum*, es el acto por el cual se somete al electorado la decisión sobre determinada cuestión de relevancia institucional. Según los alcances de la consulta varía la denominación, aunque no existe en ello uniformidad en la doctrina. No obstante, se utiliza la voz "*consulta*" o "*referéndum*" cuando se trata de cuestiones legislativas (reservándose el primer término para cuando no es vinculante y el segundo para cuando sí lo es) y "*plebiscito*" cuando se trata de cuestiones no legislativas (por ejemplo territoriales o político institucionales) o referidas a una persona en particular (voto de confianza a un gobernante). Podemos diferenciar entre referéndum "*ante legem*" y "*post legem*".

También existe referéndum constitucionales, cuando la consulta popular es una de las etapas a cumplir en el proceso de reforma constitucional. Ejemplo de ello fueron, desde antiguo, las constituciones de Mendoza y de Buenos Aires.

La ley declarativa de la necesidad de dicha enmienda, 24.309, habilitó estos temas para su debate por la Convención Constituyente, utilizando una

terminología muy general, posibilitando un amplio campo de actuación que aquella utilizó, pero limitadamente ("Paquete cerrado" de las "Coincidencias Básicas" que concretaron el entonces denominado "Pacto de Olivos"). Dicho debate y la consecuente aprobación de las normas relativas a la Consulta y a la Iniciativa Popular, se concretaron en la sesión del 26 de julio de 1994.

Ahora bien, a nivel expositivo, comenzaremos por el tema de la democracia, abordándose el mismo desde sus antecedentes históricos, doctrina, explicando las diferencias entre las distintas formas de democracia, para llegar a introducimos en el tema en cuestión.

La segunda parte contendrá análisis de casos jurisprudenciales que consideramos producto de un mandato implícito o explícito constitucional, o de una corriente doctrinaria que haya traído aparejada la sanción de dicha norma.

En una tercera parte se enfocará al análisis sobre la nueva Ley de Consulta Popular (Nº 25.432), confeccionando además los puntos que tendrá que contener la futura reglamentación de la misma por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Para finalizar, se arribará a una serie de conclusiones sobre los asuntos aquí tratados, con una visión positiva y optimista de este instituto, destacando sus logros y sus perjuicios.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las manifestaciones de democracia en las distintas culturas, como ya se ha señalado, tienen vertientes diferentes: pueden ser "*directas*" o "*indirectas*". Serán directas aquellas en que el ciudadano (1) participa sin intermediarios en las decisiones, sin ser representado por otro ciudadano. Este sistema fue el utilizado en la democracia de la Grecia Clásica, donde la importancia de ser ciudadano consistía precisamente en poder tomar decisiones; con el paso de los siglos, este sistema ha caído en desuso, pues sería muy complicado con el incremento demográfico poder reunir a todos los ciudadanos para ponerse de acuerdo y gobernar un Estado. En la propia Atenas, la democracia directa no sobrevivió mucho al crecimiento territorial del propio Estado ateniense, y el sistema, que había sido perfectamente adecuado para el gobierno de la diminuta *polis*, se reveló impráctico con el desarrollo de un Imperio marítimo extenso.

(1) El vocablo ciudadano no tenía en aquella época la extensión que ahora denota, ya que no participan todos los pobladores de un territorio sino los ciudadanos que adquieren tal rango, es decir, estaban excluidos las mujeres, los no propietarios y los esclavos. Aquel ciudadano manejaba directamente la "cosa pública" en su pueblo o ciudad-estado. En el ámbito municipal surtían el importante efecto de acercar al vecino a la cosa pública y hacerlo sentir actor de la política y el gobierno.

La palabra "idiota" se usaba para designar a quien no participaba de la vida pública (GARCÍA HAMILTON, JOSÉ I., *Por qué crecen los países*, Buenos Aires, 2006.

En cuanto a la democracia indirecta, será aquella en que el pueblo elige a sus representantes, quienes se encargarán de gobernarlo. Es el sistema que rige actualmente en las democracias contemporáneas.

El término democracia fue utilizado en forma negativa durante toda la Antigüedad, la Edad Media e incluso la Modernidad. Se prefería utilizar el término "república" para referirse al "gobierno popular bueno" definido por Polibio (2).

Rousseau realiza una clasificación entre las distintas formas de gobierno indicando que "el soberano puede, en primer lugar, nombrar para las funciones de gobierno a todo el pueblo, o a la mayor parte de él, de modo que haya más ciudadanos magistrados que simples ciudadanos particulares. Se da a esta forma de gobierno democracia" (3).

Pero para obtener una democracia que resultara efectiva se necesitaba "en primer lugar un estado muy pequeño, en que el pueblo sea fácil de congregar y en el que cada ciudadano pueda fácilmente conocer a los demás; en segundo lugar, una gran sencillez de costumbres que evite multitud de asuntos y de discusiones espinosas; además, mucha igualdad en las categorías y en las fortunas, sin lo cual la Igualdad no podría subsistir por mucho tiempo en los derechos y en la autoridad; finalmente, poco o ningún lujo, porque el lujo es efecto de las riquezas, o las hace necesarias; corrompe a la vez al rico y al pobre: a uno por su posesión y al otro por la envidia" (4).

El ideal democrático del hombre moderno ha ido cambiando y se ha transformado en el de proporcionar a cada individuo la seguridad de su libertad.

El Estado representativo tiene sus inicios en Inglaterra bajo una forma de una monarquía constitucional parlamentaria, y en Estados Unidos, bajo la forma de república presidencialista. Se nota en la utilización del lenguaje en aquella época un cambio: se hablaba de "república representativa" al referirse a lo que hoy conocemos como democracia, dado que este último término significaba el autogobierno directo de la ciudad antigua.

La democracia en un Estado representativo no se basa en el principio de "identidad", el cual se caracteriza por el vínculo directo y cercano entre gobernantes y gobernados, sino que va asociado al término "representación", donde el representante es quien participa en las decisiones que hacen al gobierno del Estado, y es responsable ante sus representados por las mismas.

Sin embargo, muchas veces se ha puesto en tela de juicio si el representante no tiende en realidad a *anteponer* sus intereses individuales a los de la

(2) Un análisis más exhaustivo en CARNOTA y MARANIELLO, *Participación Ciudadana*, Buenos Aires, 2006.

(3) ROUSSEAU, JEAN JACQUES, *El contrato social*, Libro Tercero, Capítulo III, p. 64, traducción por María José Villaverde, Barcelona, 1993.

(4) ROUSSEAU, JEAN JACQUES, op. cit.

que resulta fascinante sobre quienes encaran el desarrollo de algunos sistemas de gobierno, que intentan entonces aproximarse lo más posible a esta forma teóricamente "ideal" que sería el autogobierno:

- a) El modelo de la democracia de consejos, entre cuyos componentes esenciales hay dos que son irrenunciables: el mandato imperativo y la revocabilidad del mandato de los representantes (5);
- b) El gobierno de asamblea, donde se adoptan decisiones por aclamación o rechazo en asambleas públicas populares, donde el pueblo se expresa a viva voz (6);
- c) Consulta popular.

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN LA ARGENTINA

Si nos remontamos a nuestra historia, encontramos que el 25 de mayo de 1810, el pueblo argentino ratificó por aclamación a la Nueva Junta Gubernativa de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en un acto que podríamos denominar de *democracia directa*.

Otro antecedente lo constituye el sometimiento a la voluntad popular de la ley sancionada por la Legislatura de Buenos Aires el 7 de marzo de 1835. Dicha ley nombraba a Juan Manuel de Rosas gobernador y capitán general por el término de cinco años, y con la suma del Poder Público. Rosas exigió entonces una reconsideración de la ley y, a la vez, una *ratificación popular* de la misma, de modo de hacer constar el libre pronunciamiento de la opinión general.

En la Constitución de 1853/60, no se incorporaron los institutos del Referéndum, Plebiscito o Iniciativa Popular, mas aún hay autores que los consideraban violatorios de los arts. 1º y 22 de la Constitución, por los que se adopta la forma Representativa de Gobierno.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no se expidió hasta la fecha sobre la constitucionalidad o no de esta forma de democracia semidirecta, si bien en "Baeza c. Estado Nacional" del 28/08/84 (Fallos: 306:1125), encontramos opinión en los doctores Fayt y Belluscio: "...que el advenimiento de la democracia contemporánea ofrece una perspectiva no prevista por el constitucionalismo clásico y obligará a reconocer a toda persona, legalmente capacitada, a tomar parte directamente en el gobierno de su país, mediante el Referéndum o cualquier otro medio de consulta o participación popular..."

(5) MARTÍNEZ PERONI, JOSÉ LUIS y otros, *Derecho Constitucional de la Reforma de 1994*, Buenos Aires, 1995, t. I, p. 409. "Formas de participación directa en la democracia representativa", en PÉREZ GUILHOU, DARDO, y otros.

(6) *Ibidem*.

Contienen el instituto de consulta popular, en forma expresa, las constituciones de Suiza, Francia, España, Canadá, Australia, Uruguay, Brasil, Chile e Italia, entre otras.

En cuanto a la utilización práctica de estos mecanismos en otros países resultan curiosos algunos casos, entre ellos:

Hitler utilizó la consulta popular para la desvinculación de Alemania de la Sociedad de las Naciones, en 1933.

De Gaulle propuso al pueblo francés ciertas modificaciones en el Senado y la regionalización del país. Lo curioso del caso estuvo en que anunció que si su propuesta era rechazada, él renunciaría; con lo cual transformó una consulta popular en un plebiscito sobre su continuación o no en el cargo.

En Italia se consultó a la ciudadanía sobre la derogación o no de la ley de divorcio.

En Suiza, se consultó sobre: la limitación de la semana laboral a 40 horas, la coestión obrera, la abrogación del secreto bancario, la protección de consumidores e inquilinos. Todo ello fue rechazado por el electorado.

En el estado de California (EE.UU.) se consultó sobre la intervención o no del Estado en el mercado inmobiliario (es decir, versó sobre una medida muy concreta de gobierno).

5. DERECHO SUIZO

Existen en Suiza dos tipos diferentes de referéndum:

- *Obligatorio*: Es el que establece la propia Constitución Federal Suiza en su art. 123 para la aprobación de las reformas constitucionales.
- *Facultativo*: Es el utilizado en el ámbito legislativo, para determinar si se derogan o no leyes votadas por el gobierno federal, o decisiones políticas fundamentales tomadas por el Parlamento y promulgadas por el Poder Ejecutivo Federal (Consejo Federal o Directorio). A nivel federal son objeto de este referéndum las leyes y los tratados federales de duración indefinida o superior a quince años, y los decretos del alcance general que no tenga carácter de urgentes (art. 89).

El sometimiento de la ley a referéndum debe ser solicitado por 30.000 electores en 8 Cantones, al Consejo Federal y dentro de un plazo de 90 días, pasados los cuales la ley entra en vigor (art. 87 de la Constitución suiza). Reunidos los mencionados requisitos, el Consejo Federal organiza el referéndum, tomando la decisión por mayoría simple. Cabe señalar que en los Cantones se sigue un método similar.

176

El referéndum suizo es un instrumento público de uso habitual. Desde la reforma constitucional de 1874, se han aprobado por este medio más de 60 modificaciones o enmiendas menores a la Constitución, y en otras tantas el pueblo suizo fue convocado para expresar su opinión a través de referéndum. Es en virtud de lo expuesto que se ha dicho que el referéndum es un mecanismo político corriente de Suiza, que deberíamos tomar como ejemplo.

6. FORMAS DIRECTAS EN LOS ACTUALES SISTEMAS DEMOCRÁTICOS

En el decurso histórico, el ejercicio del poder político ha transcurrido por carriles virtualmente representativos. Las democracias occidentales vigentes son representativas, es decir, son "indirectas", en las que el pueblo está gobernado por representantes, no por sí mismo.

En Argentina ello se observa en los arts. 1º y 22 de la Constitución Nacional. El art. 1º (7) nos indica que la forma de gobierno va a ser representativa y en el art. 22 (8) se estaría excluyendo el plebiscito, aunque éste se hallaría implícito en el art. 33 (9) de la misma norma constitucional.

Existen diversas tesis con respecto a si nos debemos referir a estas prácticas como una forma directa o semidirecta de participación. Es así como José Luis Martínez Perón (10) nos habla de las mismas como de formas de participación directa. Dicho autor define como instituciones de participación directa a aquellos mecanismos instrumentales que hacen posible el acceso directo y pleno de los interesados en la adopción de las decisiones colectivas, como el veto popular, la iniciativa de las leyes y la colaboración en la formación y aprobación de las mismas. Estas han nacido como un medio de asignar al pueblo mayor participación y protagonismo en las tareas políticas.

Por intermedio de estas formas de participación, el pueblo emite juicios, toma decisiones que de otro modo serían imposibles, realiza planteos, resuelve, arbitra, deja sin efecto, toma parte en la normativa del Derecho y controla a los representantes. La participación popular en este sentido es entendida como un complemento a las aristas disfuncionales del sistema representativo. Nosotros sostenemos la misma postura, al considerar que es directa por tratarse de la manera en que el pueblo va a manifestar su voluntad nata sin tener que elegir un representante, el cual puede tergiversar su voluntad.

(7) Art. 1º de la Constitución Nacional: "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución".

(8) Art. 22 de la Constitución Nacional: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución...".

(9) Art. 33 de la Constitución Nacional: "Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno".

(10) MARTÍNEZ PERÓN, JOSÉ LUIS, obra y tomo citados en nota núm. 5.

En los sistemas políticos del siglo XX, la participación adopta las siguientes formas principales:

- a) *Plebiscito*: Este consiste en un método excepcional de decisión respecto a la viabilidad de un acto de gobierno de mayor contenido político que jurídico.
- b) *Referéndum*: Se refiere a la facultad acordada al cuerpo electoral para participar en la actividad legislativa o administrativa ratificando o rechazando proyectos o actos de los órganos legislativo o administrativo.
- c) *Iniciativa Popular*: Se encuentra definida como la facultad otorgada a cierto número de ciudadanos para proponer "motu proprio" a los poderes constitucionales la adopción, la modificación o la derogación de una norma con jerarquía constitucional, legal, administrativa o municipal.
- d) *Recall*: La revocatoria es el mecanismo por el cual un grupo de ciudadanos puede provocar una votación popular en la que se decide si un funcionario será destituido antes de la expiración legal de su mandato, o sobre la abolición de un acto de gobierno.

Las instituciones de participación directa enunciadas precedentemente se pueden citar como las más significativas, siendo las demás de importancia secundaria, como el caso del "Landsgemeinde", bien complemento de alguna de las anteriores, como la consulta popular, o bien subsumidas en las instituciones principales mencionadas, "veto popular" y "Droit Rappel".

7. FORMAS SEMIDIRECTAS EXPLÍCITAS

Sin embargo, no todos los autores comparten la misma tesis con respecto a las formas de participación de los ciudadanos en la democracia. Para la doctrina clásica, las formas participativas aceptadas por la Constitución Argentina son consideradas como una forma semidirecta de participación de sus ciudadanos en la democracia. En este apartado, veremos el punto de vista de la doctrina clásica, representado por Ekmekdjian, acerca de los mecanismos constitucionales de consulta popular.

Los mismos han sido incorporados en la reforma Constitucional de 1994 dentro del nuevo art. 40, el cual dispone:

"El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de

177

cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular".

a) Referéndum

Dicho artículo incorpora dos institutos de democracia semidirecta: "el referéndum" y "el plebiscito", aunque existe un defecto jurídico por parte del constituyente al otorgar a los dos institutos la misma denominación de "consulta popular". El referéndum es el proceso de consulta a los ciudadanos, a efectos de que éstos se expresen sobre actos de gobierno de carácter legislativo. En nuestro referéndum la actividad legislativa no es exclusiva, como lo es en ciertos cantones suizos, donde las formas de gobierno cantonal varían, pero cada uno de los 20 cantones y 6 semicantones tienen un consejo legislativo electo y un consejo ejecutivo. En los cantones más pequeños el consejo legislativo (o *Landsgemeinde*) es una asamblea general de ciudadanos que deciden sobre los asuntos mediante votación oral. Sin embargo, en la mayoría de los cantones el consejo legislativo es un cuerpo representativo elegido por votación popular. No se trata aquí de una forma indirecta como en las instituciones representativas, sino que el cuerpo electoral actúa como colegislador. En el referéndum los representantes sancionan la ley, pero *ad referéndum* de la aprobación de los ciudadanos, siendo su voto afirmativo una condición suspensiva a la cual se somete la validez y eficacia de la norma jurídica.

Ekmedjian sostiene que el referéndum puede ser clasificado de diversas formas (11):

- Con relación a su objeto, puede ser constitucional, legislativo, administrativo o municipal, según el acto al que se refiera.
- Por sus efectos, puede ser constitutivo, modificatorio o de veto, según que el voto afirmativo sancione, altere o extinga una norma jurídica. El referéndum constitutivo se conoce también como *ante legem*; el modificatorio y el de veto, como *post legem*.
- Por su naturaleza jurídica, puede ser facultativo u obligatorio, según que la Constitución deje librado al criterio del Poder Legislativo convocar a un referéndum o, al contrario, lo exija como *conditio sine qua non* para la sanción de determinadas normas. Asimismo, se cita como ejemplo a las normas constitucionales que prevén reformas o enmiendas de la Carta Magna, por el poder legislativo con mayorías y quórum agravados, sujetas a referéndum del cuerpo electoral. En nuestro país, este mecanismo fue utilizado por algunas provincias para realizar enmiendas parciales, y ha sido incorporado a sus Constituciones Provinciales.
- Por la calidad de las personas que lo impulsan, puede ser popular, congresional o presidencial.

(11) EKMEKDJIAN, MIGUEL ANGEL, *Tratado de Derecho Constitucional de la Nación Argentina*, comentada y anotada con legislación, jurisprudencia y doctrina, t. III (arts. 28 a 41), p. 624, Buenos Aires, 1995.

El referéndum tuvo su origen en Suiza en el siglo XVI, y es en ese país en donde ha alcanzado su mayor desarrollo. Se pueden encontrar antecedentes del referéndum en las instituciones democráticas de la antigua Grecia, las prácticas de tribus germánicas, los consejos municipales de la Nueva Inglaterra colonial. En los Estados Unidos, el referéndum se ha generalizado en el ámbito estadual, incluso para la reforma de las constituciones locales, pero dicho instituto no existe en el ámbito federal (nunca se ha utilizado el sistema de referéndum en el ámbito nacional).

En nuestro país, dentro del primer párrafo del art. 40 de la Constitución Nacional se expresa que "El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley...". Este es un avance en que se introduce expresamente el referéndum legislativo como una forma de democracia semidirecta. Asimismo, este referéndum resulta ser legislativo porque se limita a los proyectos de ley que son competencia del Congreso Nacional; y es constitutivo o *ante legem*, porque lo que se somete al cuerpo electoral es el proyecto de ley, antes de ser votado por las cámaras legislativas. En otro orden de cosas, es *facultativo* porque la Constitución Nacional no lo exige obligatoriamente, sino que lo deja librado a la prudencia política del Congreso, y es congresional porque el único que puede someter el proyecto de ley al cuerpo electoral es el Congreso.

b) Trámite parlamentario

La iniciativa popular consiste en el derecho reconocido a los electores para presentar proyectos legislativos a la Cámara de Diputados, para que luego ambas cámaras la consideren. En general, esta iniciativa necesita de un mínimo de adhesiones para ser considerada como tal. Este mecanismo, de acuerdo a su regulación, obliga al cuerpo legislativo a tomar una decisión o a convocar a referéndum.

La Cámara de Diputados tiene como atribución exclusiva ser la iniciadora para someter un proyecto a referéndum del cuerpo electoral. Por tal motivo, quedan excluidos del referéndum los proyectos que tienen al Senado como Cámara iniciadora (nuevo art. 75 inc. 2 de la Constitución Nacional). Asimismo, este artículo viene a introducir una característica que resulta novedosa, consistente en la prohibición del veto presidencial a la ley que convoca al cuerpo electoral a comicios para decidir sobre el referéndum. Esta disposición implica una limitación a la facultad de veto prevista en los arts. 80 (12) y 83 (13) de la Constitución Nacional, que vimos *supra*.

(12) Art. 80 de la Constitución Nacional: "Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia".

(13) Art. 83: "Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: esta lo discute de nuevo, y si lo confirma por